상속세 및 증여세법의 헌법상의 문제에 관한 연구*

정 상 익**

국 문 초 록

산업이 고도화함에 따라 경제활동의 중요성이 더욱 커졌고, 경제활동의 중요성이 커지면서 국민들이 부와 재산을 중시하는 경향이 더욱 증가하였다. 또한 정부의 역할이 증대함에 따라 공공부문의 자금수요가 증가하였고, 공공부문의 자금수요가 증가하면서 정부가 세입을 확대하는 경향도 증가하고 있다. 국민들이 부와 재산을 중시하는 경향의 증가와 정부가 세입을 확대하는 경향은 서로 상승작용을 일으켜 조세에 관한 헌법재판이 적지 않게 청구되고 있다. 조세에 관한 헌법재판 중에서 상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판이 차지하는 비중이 작지 않다. 조세에 관한 헌법재판에서는 헌법과 조세법이 매우 밀접하게 상호작용을 하고 있다. 헌법재판소는 조세에 관한 헌법상의 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 조세법으로부터 여러 도움을 받고 있다. 또한 조세법상의 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 헌법재판이 큰 기여를 하고 있다. 그리고 조세에 관한 헌법재판소의 결정을 통하여 헌법에 관한 이론이 개발되고 세련화되고 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정들은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 조세법 이외의 분야에 적용되는 헌법이론이 조세에 관한 헌법재판에 별다른 수정없이 그대로 적용되고 있는 경우와 조세법의 특수성을 반영한 경우로 분류할 수 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정들 중에서 조세법의 특수성을 반영한 헌법재판소의 결정은 그리 많지 않다. 이러한 현상의 이유는 헌법 자체가 조세에 관하여 별다른 규정을 마련하고 있지 않기 때문일 것이다. 헌법에 명문으로 조세에 관한 규정을 마련한다는 것이 쉬운 일은 아니다. 헌법에 명문으로 조세에 관한 규정이 많지 않다는 것은 조세에 관한 헌법적 문제를 해결할 때 어려움을 초래할 수도 있다. 조세는 국민의 재산이 무상으로 국가로 이전되는 것이라는 점에서 국민의 재산권과 밀접한 관련이 있는바, 국민의 재산권의 보장에 만전을 기하기 위하여 조세에 관한

---

* 투고일자:7.31, 심사일자:8.10, 게재확정일자:8.13

** 홍익대학교 법과대학 부교수.

헌법재판의 이론의 개발과 발전이 이루어져야 할 것이다.

상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판의 유형은 3가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 상속세 및 증여세법에 대한 위헌법률심판이 있다. 이것은 상속세 및 증여세법이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 되었을 때에 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 당해 사건을 담당하는 법원이 위 법률에 대하여 위헌여부의 심판을 제청하여 시작되는 헌법재판이다. 둘째, 상속세 및 증여세법에 대한 위헌심사형 헌법소원심판이 있다. 이것은 법원이 법률의 위헌여부심판의 제청신청을 기각한 경우에 위헌법률심판을 직접 헌법재판소에서 받고자 하여 청구하는 헌법소원심판이다. 셋째, 공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자가 청구하는 권리구제형 헌법소원심판이 있다. 입법, 행정, 사법 등이 적극적으로 공권력을 행사한 경우나 소극적으로 행사하지 아니한 부작위의 경우 그로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받았다면 권리구제형 헌법소원심판을 청구할 수 있다.

상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판의 특징으로 여러 가지를 지적할 수 있다. 첫째, 위헌심사형 헌법소원심판이 위헌법률심판이나 권리구제형 헌법소원심판보다 그 수가 많다는 점이다. 위헌법률심판이 적고 위헌심사형 헌법소원심판이 많다는 것은 계쟁사건의 법원이 당사자의 위헌법률심판 제청신청을 잘 받아들이지 않기 때문이다. 둘째, 상속세 및 증여세법에 관한 심판제청 또는 청구의 사유는 대체적으로 몇 가지에 국한되어 있다는 점이다. 셋째, 헌법과는 직접적인 관련이 없는 것들도 심판제청 또는 청구의 사유로서 주장되고 있다는 점이다. 넷째, 법규범 상호간의 효력순위와 법규범 상호간의 관계와 관련된 것이 심판 제청 또는 청구의 사유로서 주장되고 있다는 점이다. 다섯째, 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판에서는 심판제청 및 청구사유로서 기본권조항보다는 비기본권조항 위반이 자주 주장되고 있다는 점이다. 비기본권조항 위반을 주장하는 것이 좀더 쉽기 때문에 그러한 것인지 여부는 알 수 없지만 심판제청 및 청구사유로서 비기본권조항을 좀더 선호하는 것으로 보인다. 또한 심판제청 및 청구사유로서 주장되고 있는 기본권조항은 재산권보장 조항이 많고, 평등권도 자주 주장되며, 재판청구권이 종종 주장되고 있다. 여섯째, 헌법재판소는 제청법원 또는 청구인이 주장하고 있는 심판제청 또는 청구사유를 중심으로 위헌주장의 타당성 여부를 판단하고 있다는 점이다. 헌법재판소의 판단이 제청법원 또는 청구인의 심판제청 또는 청구사유에 제한되는 것이 아님에도 불구하고 헌법재판소는 제청법원 또는 청구인이 주장하지 않고 있는 위헌사유를 스스로 찾아 내서 위헌여부의 판단을 하지는 않는다.

상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판의 주요문제로는 조세법률주의, 기본권의

본질적 내용 침해금지와 조세법률주의의 관계, 조세입법에 있어서의 위임입법, 기본권 제한의 한계, 편의주의, 정의의 원칙, 이중과세, 조세평등주의, 실질과세의 원칙 등이 있다. 이러한 문제들은 앞으로도 계속하여 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판에서 다루어질 것이기 때문에 중요한 것들이다. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판 그리고 더 나아가 조세법 전반에 대한 헌법재판에서 문제가 되는 것들은 궁극적으로 헌법의 이론과 헌법의 해석에 의하여 해결되어야 하지만 헌법의 이론과 헌법의 해석 못지 않게 조세법의 이론과 조세법의 해석의 도움이 필요하고 조세학의 이론의 도움이 필요하다. 다시 말하면 조세법에 대한 헌법재판에서 문제가 되는 것들을 해결하기 위하여는 헌법의 이론과 헌법의 해석, 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론의 도움이 필요하다. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판소의 결정들을 보면 비록 헌법재판소 자체의 입장이 일치되지 못하고 있는 것들도 있지만 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론을 헌법적인 수준으로 끌어 올리기 위하여 많은 노력을 기울이고 있음을 확인할 수 있다. 그런데 이러한 노력이 쉬운 일은 아니다. 조세에 관한 헌법의 규정이 얼마 되지 않고, 조세에 관한 헌법의 규정의 내용이 명확하지 않은 상태에서 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론을 헌법적인 수준으로 끌어 올리는 것은 어려운 작업이다. 조세법에 대한 헌법재판에서 제기된 문제들을 해결하기 위하여는 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 것들을 헌법의 규정과 관련된 것들과 그렇지 않은 것들로 구분하는 작업이 필요하다. 이러한 작업의 결과 어떤 것들은 헌법의 내용으로 되고, 다른 것들은 헌법과는 무관한 것이 된다. 헌법의 내용으로 된 것들은 헌법재판에서 위헌심사의 기준이 되고, 헌법과 무관한 것들은 헌법재판에서 위헌심사의 기준이 되지 못한다. 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 용어들이 헌법상의 용어들과 정확히 일치하지 않기 때문에 어려움이 가중된다. 이러한 어려움들을 해결하기 위하여 꾸준한 노력이 필요하다. 조세에 관한 헌법규정들의 의미에 관한 연구와 이를 구현시키기 위한 방법이 계속적으로 모색되어야 할 것이다.

▶ 주 제 어 ◀

상속세, 증여세, 조세법률주의, 기본권, 위임입법, 이중과세, 조세평등주의.

▶목 차◀

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판의 유형
Ⅲ. 상속세 및 증여세의 의의
Ⅳ. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판의 심판제청 또는 청구사유
Ⅴ. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판의 주요문제
Ⅵ. 결 론

Ⅰ. 서론

헌법재판소의 결정 중에서 조세에 관한 결정이 적지 않다. 이러한 현상은 산업의 고도화와 정부의 역할 증대와 관련이 있는 것으로 보인다. 산업이 고도화함에 따라 경제활동의 중요성이 더욱 커졌고, 경제활동의 중요성이 커지면서 국민들이 부와 재산을 중시하는 경향이 더욱 증가하였다. 또한 정부의 역할이 증대함에 따라 공공부문의 자금수요가 증가하였고, 공공부문의 자금수요가 증가하면서 정부가 세입을 확대하는 경향도 증가하고 있다. 국민들이 부와 재산을 중시하는 경향의 증가와 정부가 세입을 확대하는 경향은 서로 상승작용을 일으켜 조세법에 관한 헌법재판소의 결정이 적지 않았던 것으로 보인다.

조세에 관한 헌법재판소의 결정이 적지 않다는 것은 헌법과 조세법을 연구하는데 있어서 몇 가지 중요한 의미를 가진다.

첫째, 조세에 관한 헌법상의 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 조세법이 큰 기여를 하고 있다. 헌법재판소는 조세에 관한 헌법상의 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 조세법으로부터 여러 도움을 받고 있다.

둘째, 조세법상의 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 헌법재판이 큰 기여를 하고 있다. 조세법의 분야에서 이론을 개발하고 발전시키는데 있어서 헌법재판으로부터 여러 도움을 받고 있다.

셋째, 조세에 관한 헌법재판소의 결정을 통하여 헌법에 관한 이론을 개발하고 발전시키고 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정을 통하여 헌법에 관한 이론이 개발되고 세련화되고 있다.

위에서 본 의미들로부터 헌법과 조세법이 매우 밀접하게 상호작용을 하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

조세에 관한 헌법재판소의 결정들은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 조세법 이외의 분야에 적용되는 헌법이론이 조세에 관한 헌법재판에 별다른 수정없이 그대로 적용되고 있는 경우와 조세법의 특수성을 반영한 경우로 분류할 수 있다. 조세법 이외의 분야에 적용되는 헌법이론이 조세법에 관한 헌법재판에 별다른 수정없이 그대로 적용되고 있는 경우의 예로는 조세평등주의, 위임입법의 한계와 관련된 경우 등을 들 수 있다. 조세법의 특수성을 반영한 경우의 예로는 미실현소득의 과세문제, 이중과세문제, 과세관할권의 문제, 국제조세에 있어서의 준거법의 문제, 소급과세의 문제 등을 들 수 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정을 통한 헌법과 조세법의 상호작용 속에서 미흡한 것이 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정들을 살펴 보면, 헌법재판소의 결정들 전부가 그런 것은 아니지만 조세법 이외의 분야에 적용되는 헌법이론이 조세법에 관한 헌법재판에 별다른 수정없이 그대로 적용되는 경우가 많다는 것을 알 수 있다. 조세에 관한 헌법재판소의 결정들 중에서 조세법의 특수성을 반영한 헌법재판소의 결정은 그리 많지 않다. 이러한 현상의 이유는 헌법 자체가 조세에 관하여 별다른 규정을 마련하고 있지 않기 때문일 것이다. 헌법에 명문으로 조세에 관한 규정을 마련한다는 것이 쉬운 일은 아니다. 조세의 분야가 국가에서 차지하는 비중이 날로 증가하는바, 헌법에 명문으로 조세에 관한 규정이 많지 않다는 것은 조세에 관한 헌법적 문제를 해결할 때 어려움을 초래할 수도 있다. 조세는 국민의 재산이 무상으로 국가로 이전되는 것이라는 점에서 국민의 재산권과 밀접한 관련이 있는바, 국민의 재산권의 보장에 만전을 기하기 위하여 조세에 관한 헌법재판의 이론의 개발과 발전이 이루어져야 할 것이다. 이하에서는 조세에 관한 헌법재판소의 결정 중에서 상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판소의 결정을 분석하고자 한다. 1989년에 선고된 결정 1개, 1992년에 선고된 결정 1개, 1994년에 선고된 결정 1개 그리고 1995년부터 1998년까지 선고된 결정 10개가 분석의 대상이 된다. 본 논문에서 분석하고 있는 결정들은 주로 1995년부터 1998년까지 선고된 결정들이며, 나머지 결정 3개는 위헌사유가 특색이 있어 분석의 대상으로 포함한 것이다. 본 논문에서 다루지 않은 결정들은 다음의 기회로 미루고자 한다. 본 논문은 헌법재판에서 주장되었던 상속세 및 증여세법에 관한 심판제청 또는 청구사유와 이에 관한 헌법재판소의 판단을 분석하고, 이를 통하여 상속세 및 증여세에 관한 헌법상의 문제들을 확인하고, 이러한 문제들이 가지고 있는 의미를 살펴 본다.

Ⅱ. 상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판의 유형

상속세 및 증여세법에 관한 헌법재판의 유형은 3가지로 나누어 볼 수 있다. 이러한 유형은 상속세 및 증여세를 제외한 나머지 조세분야에서의 헌법재판 그리고 조세 이외의 분야에서의 헌법재판과 동일하다.

첫째, 상속세 및 증여세법에 대한 위헌법률심판이 있다. 이것은 상속세 및 증여세법이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 되었을 때에 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 당해 사건을 담당하는 법원이 위 법률에 대하여 위헌여부의 심판을 제청하여 시작되는 헌법재판이다. 우리 나라의 경우 추상적 규범통제를 인정하지 않고 구체적 규범통제만을 인정하고 있다. 따라서 헌법재판소가 법률조항의 위헌여부를 심판하기 위하여는 문제된 법률조항이 헌법에 위반되는지 여부가 구체적 사건의 해결을 위한 재판의 전제로 되어야 한다.[1] 재판의 전제성이 인정되기 위하여는 구체적인 사건이 법원에 계속 중이어야 하고, 위헌의 다툼이 있는 당해 법률이 당해 소송사건의 재판과 관련하여 적용되는 것이어야 하며, 그 법률이 헌법에 위반되는지의 여부에 따라 당해사건을 담당한 법원이 다른 내용의 재판을 하게 되는 것이어야 한다.[2]

둘째, 상속세 및 증여세법에 대한 위헌심사형 헌법소원심판이 있다. 이것은 법원이 법률의 위헌여부심판의 제청신청을 기각한 경우에 위헌법률심판을 직접 헌법재판소에서 받고자 하여 청구하는 헌법소원심판이다. 따라서 위헌심사형 헌법소원심판을 청구하기 위하여는 소송사건의 당사자가 위헌여부심판의 제청신청을 하였음에도 불구하고 법원이 이를 배척하였어야 한다.[3] 위헌심사형 헌법소원심판의 경우에도 재판의 전제성이 있어야 한다.[4]

셋째, 공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자가 청구하는 권리구제형 헌법소원심판이 있다. 이것은 그 대상에 따라 입법작용에 대한 헌법소원, 집행작용에 대한 헌법소원, 사법작용에 대한 헌법소원 등으로 나누어진다.[5] 입법, 행정, 사법 등이 적극적으로 공권력을 행사한 경우나 소극적으로 행사하지 아니한 부작위의 경우 그로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받았다면 권리구제형 헌법소원심판을 청구할 수 있다. 공권력의 행사를 대상으로 하는 헌법소원에 있어서는 적어도 기본권침해의 원인이 되는 행위가 공권력의 행사에 해당하

1) 김철수, 제19전정신판 헌법학개론, 박영사, 2007, p. 1669.
2) Ibid., p. 1674.
3) Ibid., p. 1721.
4) Ibid., p. 1725.
5) 권영성, 개정판 헌법학원론, 법문사, 2007, p. 1152.

여야 하고, 그러하지 아니하면 권리구제형 헌법소원심판청구는 부적법함을 면할 수 없다.[6] 권리구제형 헌법소원심판을 하기 위하여는 공권력의 행사 또는 불행사로 말미암아 헌법상 보장된 자신의 기본권이 직접적이고 현실적으로 침해되었을 것, 다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 마친 후일 것, 권리보호의 필요성이 있을 것 등이 요구된다.[7] 권리구제형 헌법소원심판은 재판의 전제성을 필요로 하지 않지만 보충성의 원칙이 적용되 다다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 마쳐야 하며, 그 절차를 마치지 아니하였을 경우에는 권리구제형 헌법소원심판을 청구할 수 없다. 것 부과처분이 없t수 없다. 것 부과처분이그 규정 자체로 직접 기본권을 침해하였을 경우 이에 대하여 마련된 구제절차는 없으므로 권리구제형 헌법소원심판을 활용할 수 있고, 것 부과처분이 없t수 없다. 것 부과처이 직접적 시행령이나 시행규칙이 그 규정 자체로 직접 기본권을 침해하였을 경우 이에 대하여 마련된 구제절차는 없으므로 권리구제형 헌법소원심판을 활용할 수 있다. 상속세 및 증여세법에 있어서의 진정입법부작위의 경우에도 권리구제형 헌법소원심판을 활용할 수 있다. 진정입법부작위란 입법자가 헌법상 입법의무가 있는 어떤 사항에 관하여 전혀 입법을 하지 아니함으로써 입법행위의 흠결이 있는 경우를 말한다.[8]

위에서 본 3가지 유형의 헌법재판에서 가장 큰 차이는 심판대상의 차이와 심판제청 또는 청구사유의 차이이다. 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판에 있어서는 위헌법률이 심판의 대상이 되는데, 권리구제형 헌법소원심판에 있어서는 공권력의 행사 또는 불행사가 심판의 대상이 된다. 공권력의 행사에는 입법작용인 법률이 포함되지만 공권력의 행사가 법률에 국한되는 것은 아니다. 공권력의 행사는 법률보다 넓은 개념이다. 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판에 있어서는 헌법에 위반되는 여부가 심판제청 또는 청구사유가 되는데, 권리구제형 헌법소원심판에 있어서는 헌법상 보장된 기본권을 침해하였는지 여부가 심판청구사유가 된다. 헌법에는 기본권이 포함되지만 헌법이 기본권에 국한되는 것은 아니다. 헌법은 기본권보다 넓은 개념이다. 헌법에는 기본권에 관한 규정 뿐만 아니라 비기본권에 관한 규정도 있다. 심판대상이란 점에서 보면 권리구제형 헌법소원심판이 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판보다 더 넓다. 심판제청 또는 청구사유란 점에서 보면 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판이 권리구제형 헌법소원심판보다 더 넓다. 권리구제형 헌법소원심판은 헌법상의 기본권에 관한 규정을 위반하였는지 여부를 심판하지만 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판은 기본권 뿐만 아니라 헌법상의 모든 규정을 위반하였는지 여부를 심판한다.

---

6) 김철수, 전게서, p. 1731.
7) 권영성, 전게서, p. 1155.
8) Ibid., p. 1159.

Ⅲ. 상속세 및 증여세의 의의

상속세는 상속 또는 유증에 의하여 재산이 이전하는 사실 또는 이전하는 재산을 포착하여 과세하는 조세를 말한다. 상속 또는 유증에 의하여 재산을 취득할 경우 취득자에게는 특별한 수득이 발생하며, 그러한 요건이 과세의 대상이 되는 것이다.[9] 현행 상속세 및 증여세법 제1조(상속세 과세대상) 제1항에 의하면, 상속세는 상속(유증, 증여자의 사망으로 인하여 효력이 발생하는 증여 및 민법 제1057조의 2에 따른 특별연고자에 대한 상속재산의 분여를 포함한다)으로 인하여 상속이 개시되었을 때 상속재산에 대하여 부과하는 조세를 말한다. 상속재산에 대하여 조세를 부과하는 제도는 고대의 로마시대에 그 기원을 찾아볼 수 있으나 현대적 의미에서 상속세가 부과되기 시작한 것은 사유재산제도가 확립된 이후의 일이다. 과거에는 재산의 무상이전에 과세하지 않는 것이 보통이었고, 직계상속 또는 배우자상속에는 과세가 면제되었다. 상속세는 재산을 상속할 경우 봉건군주의 승인을 얻어야 하고 그 승인에 대한 대가를 지급하는 제도에서 유래한 것이다. 그 후 재산상속에 대한 승인료는 등기수수료가 되고, 이어서 인지세 또는 등록세의 형태로 발전하였으며, 다음에는 물적 수득세 또는 실질적 재산세로 변화하였다. 현재 각국은 모두 상속세를 소득세와 분리시키고 있다.[10] 그러나 경제사회의 발전에 따라 소득 및 재산의 재분배에 대한 국가적 관심이 제고된 이후부터 불로소득을 과세하는 목적보다는 재산의 분배를 시정하기 위한 수단으로서 상속세를 이용하게 되었다.[11]

헌법재판소는 상속세의 의의와 목적에 관하여

[상속세제도는 국가의 재정수입의 확보라는 일차적인 목적 이외에도, 자유시장경제에 수반되는 모순을 제거하고 사회정의와 경제민주화를 실현하기 위하여 국가적 규제와 조정들을 광범위하게 인정하는 사회적 시장경제질서의 헌법이념에 따라 재산상속을 통한 부의 영원한 세습과 집중을 완화하여 국민의 경제적 균등을 도모하려는데 그 목적이 있다 할 것이고, 이러한 경제·사회적 목적의 효율적인 수행을 위하여 법 제14조는 과세가액에 따라 누진세율을 적용하여 상속세를 산출하도록 규정하고 있다]라고 판시하고 있다.[12]

---

9) 차병권, 제2전정판 재정학개론, 박영사, 1992, p. 568.
10) Ibid., pp. 568-570.
11) Ibid., pp. 569.
12) 헌재 1997.12.24. 96헌가19.

위 결정에 의하면, 상속세의 일차적인 목적은 국가의 재정수입의 확보이고, 다른 목적은 재산상속을 통한 부의 영원한 세습과 집중을 완화하여 국민의 경제적 균등을 도모하려는 것이다. 위 결정은 상속세가 재산상속을 통한 부의 영원한 세습과 집중을 완화하기 위한 수단이라는 것을 명시적으로 언급함으로써 상속세가 재산의 분배를 시정하기 위한 수단이 됨을 인정하고 있다.

상속세의 형태에는 크게 2가지가 있다.[13]

첫째, 개인의 사망시에 재산처분권을 제한할 목적으로 부과되는 유산세(estate duty)가 있다. 이것은 사망자의 재산에 대해 재산분배가 시행되기 전에 피상속인의 유산 자체를 과세대상으로 부과하는 조세로 재산세적 성격을 띤다. 이것은 사망자의 재산 총액을 기준으로 하여 재산 총액에 담세력을 인정하고 과세하는 것이다. 이것은 상속 및 유증재산을 일괄하여 과세하는 것이다.

둘째, 개인의 노력 없이 유증형태로 개인이 자산을 획득하는 권리를 제한할 의도에서 상속인의 상속분에 대하여 부과되는 상속세 또는 유산취득세(inheritance tax, succession duty, legacy duty)가 있다. 이 경우에도 상속분의 크기에 따라 차별과세를 할 필요가 있으면 누진과세를 채택하면 된다. 그런데 이같은 차별과세효과는 개별적인 재산의 상속시에 누진과세를 하는 것보다 일생을 통하여 수증한 재산총액에 누진세율을 적용할 때 차별과세의 효과는 더 크다. 이와 같은 방법으로 과세하는 것을 승계세(accessions tax)라고 한다. 누진세율을 적용할 경우 수증재산의 크기보다 수증 및 그 이전의 수증을 포함하여 상속인의 순자산총액에 대하여 누진세율을 적용하는 것이 보다 효과적이다.

증여세는 타인으로부터 재산을 증여받은 경우에 증여받은 재산에 대하여 과세하는 조세이다.[14] 상속세 및 증여세법 제2조(증여세 과세대상) 제1항에 의하면, 증여세는 타인의 증여(증여자의 사망으로 인하여 효력이 발생하는 증여는 제외한다)가 있을 때 증여재산에 대하여 부과하는 조세를 말한다.

Ⅳ. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판의 심판제청 또는 청구사유

1. 위헌법률심판의 경우

1) 헌재 1992.2.25. 90헌가69.

심판제청사유: 평등권, 재산권, 재판청구권 제한 내지 박탈, 조세법률주의 위반.

---

13) Ibid., pp. 568-571.
14) Ibid., p. 573.

2) 헌재 1997.12.24. 96헌가19.

심판제청사유: 이중과세→ 조세법률주의, 평등의 원칙(조세평등주의), 재산권보장 위반.

2. 위헌심사형 헌법소원의 경우

1) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.
심판청구사유: 재산권보장, 경제적 차별금지, 실질과세의 원칙, 형평의 원칙 위반, 국법질서의 통일성과 체계성 교란, 규정 상호간 모순.
위헌법률심판 제청신청 기각 후 헌법소원한 것임.

2) 헌재 1994.6.30. 93헌바9.

심판청구사유: 실질적 조세법률주의, 재산권보장, 평등권 위반.

3) 헌재 1995.9.28. 94헌바23.

심판청구사유: 헌법전문, 연좌제 금지, 자기책임의 원칙, 과잉금지의 원칙, 실질적 조세법률주의 위반.

4) 헌재 1997.10.30. 96헌바14.

심판청구사유: 본질적 내용 침해금지, 조세법정주의 위반.

5) 헌재 1997.11.27. 95헌바38.

심판청구사유: 본질적 내용 침해금지, 비례의 원칙, 과잉금지의 원칙(목적의 정당성의 원칙, 방법의 적정성의 원칙, 법익의 균형성의 원칙, 피해의 최소성의 원칙) 위반.

6) 헌재 1998.4.30. 96헌바87.

심판청구사유: 조세평등주의, 실질과세원칙 위반.

7) 헌재 1998.4.30. 96헌바78.

심판청구사유: 조세법률주의, 위임입법의 한계 위반.

8) 헌재 1998.4.30. 95헌바55.

심판청구사유: 조세법률주의, 위임입법의 한계, 실질과세원칙 위반.

9) 헌재 1998.3.26. 96헌바57.
심판청구사유: 조세법률주의, 위임입법의 한계, 평등의 원칙 위반.

3. 권리구제형 헌법소원의 경우

1) 헌재 1995.8.16. 95헌마219.

심판청구사유: 조세법률주의, 조세평등주의, 재산권보장 위반.

2) 헌재 1998.5.28. 96헌마151.

심판청구사유: 조리, 조세법률주의, 조세평등주의, 재산권보장, 정의와 형평 위반.

4. 종합

위에서 본 사건들을 분석해 보면, 아래의 사실들을 확인할 수 있다.

첫째, 위헌심사형 헌법소원심판이 위헌법률심판이나 권리구제형 헌법소원심판보다 그 수가 많다는 점이다. 위헌법률심판이 적고 위헌심사형 헌법소원심판이 많다는 것은 계쟁사건의 법원이 당사자의 위헌법률심판 제청신청을 잘 받아들이지 않기 때문이다. 계쟁사건의 법원이 당사자의 위헌법률심판 제청신청을 받아들이면 당사자가 위헌심사형 헌법소원심판을 제기할 여지는 없다. 권리구제형 헌법소원심판이 적은 이유는 보충성의 요건 때문에 공권력의 행사 또는 불행사에 대하여 적법한 권리구제형 헌법소원심판을 청구하는 것이 쉽지 않기 때문이다. 또한 권리구제형 헌법소원심판은 위헌법률심판이나 위헌심사형 헌법소원심판과는

달리 헌법상 보장된 기본권의 침해가 있을 것을 요건으로 하고 있는바, 이러한 요건으로 인하여 권리구제형 헌법소원심판은 위헌법률심판이나 위헌심사형 헌법소원심판보다 심판청구사유의 폭을 제한받게 된다.

둘째, 상속세 및 증여세법에 관한 심판제청 또는 청구의 사유는 대체적으로 몇 가지에 국한되어 있다는 점이다. 위에서 본 사건들을 분석해 보면, 조세법률주의 위반은 10개 사건에서, 재산권보장 위반은 6개 사건에서, 조세평등주의 위반은 4개 사건에서, 위임입법의 한계 위반은 3개 사건에서, 평등의 원칙 위반은 3개 사건에서, 기본권의 본질적 내용 침해금지 위반은 3개 사건에서, 실질과세원칙 위반은 3개 사건에서 주장되었다.

셋째, 헌법과는 직접적인 관련이 없는 것들도 심판 제청 또는 청구의 사유로서 주장되고 있다는 점이다. 심판 제청 또는 청구의 사유로서 주장되고 있으나 헌법과 관련이 없다는 것이 명백할 경우에는 상속세 및 증여세법이 그것을 위반하였다고 하여도 위헌 또는 헌법상 보장된 기본권의 침해가 있다고 할 수 없다. 그런데 문제는 어떠한 것이 헌법상의 내용인지 아닌지 여부가 그리 명백한 것은 아니라는 사실이다. 이러한 문제는 헌법의 해석의 문제와 관련되어 있다. 조리, 정의와 형평, 자기책임의 원칙 등이 헌법상의 내용인지 아닌지 여부는 그리 명백하지 않다. 어떠한 것들은 헌법상의 내용이 아니라 법률상의 내용에 그치는 것들도 있다. 아울러 실질과세의 원칙, 근거과세의 원칙의 경우 이것들이 과연 헌법상의 원칙들인지 여부는 앞으로 좀더 검토하여야 할 것이다.

넷째, 법규범 상호간의 효력순위와 법규범 상호간의 관계와 관련된 것이 심판제청 또는 청구의 사유로서 주장되고 있다는 점이다. 원래 헌법재판 자체가 법규범 상호간의 효력순위에 관한 이론을 전제하고 있다. 이러한 이론에 의하면, 헌법은 최고의 법규범이다. 현재 존재하고 있는 법률에 관한 한 어떠한 구제방법도 찾을 수 없을 때 마지막으로 그 법률 자체의 효력을 부정함으로써 구제방법을 찾는 것이 헌법재판이다. 법률 자체의 효력을 부정하려면 법률보다 효력이 우위인 법규범을 상정하여야 하는데, 헌법이 바로 그것이다. 위임입법의 한계의 문제도 법규범 상호간의 효력순위와 관련되어 있다. 국법질서의 통일성과 체계성의 교란, 규정 상호간 모순 등은 법규범 상호간의 관계와 관련되어 있다.[15] 동일한 대상을 규율하고 있는 법규범이 복수가 있을 경우 어떠한 것을 적용하여야 하는가의 문제이다. 소급과세의 문제도 구법과 신법 중에서 어떠한 것을 적용하여야 하는가의 문제이다. 조세의 분야에서 다양한 형식의 양자조약 및 다자조약의 체결이 증가하고 있는데, 조세조약과 법률과의 관계도 법규범 상호간의 관계와 관

15) 법규범 상호간의 관계에 관하여는 오세혁, 규범충돌 및 그 해소에 관한 연구-규범체계의 통일성과 관련하여-, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2000 참조.

련되어 있다.[16]

다섯째, 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판에서는 심판제청 및 청구사유로서 기본권조항보다는 비기본권조항 위반이 자주 주장되고 있다는 점이다. 비기본권조항 위반을 주장하는 것이 좀더 쉽기 때문에 그러한 것인지 여부는 알 수 없지만 심판제청 및 청구사유로서 비기본권조항을 좀더 선호하는 것으로 보인다. 또한 심판제청 및 청구사유로서 주장되고 있는 기본권조항은 재산권보장 조항이 많고, 평등권도 자주 주장되며, 재판청구권이 종종 주장되고 있다. 평등권의 경우 심판제청 및 청구사유로서 평등권 위반, 평등의 원칙 위반, 조세평등주의 위반 등으로 주장되지만 헌법재판소는 평등권 위반보다는 평등의 원칙 위반 또는 조세평등주의 위반 등으로 판단하고 있다.

여섯째, 헌법재판소는 제청법원 또는 청구인이 주장하고 있는 심판제청 또는 청구사유를 중심으로 위헌주장의 타당성 여부를 판단하고 있다는 점이다. 헌법재판소의 판단이 제청법원 또는 청구인의 심판제청 또는 청구사유에 제한되는 것이 아님에도 불구하고 헌법재판소는 제청법원 또는 청구인이 주장하지 않고 있는 위헌사유를 스스로 찾아 내서 위헌여부의 판단을 하지는 않는다. 이러한 사실로부터 헌법재판에 있어서는 문제가 되는 법률조항을 찾아 내고 그 법률조항이 위헌인 이유를 논증해 가는 제청법원 또는 청구인의 역할이 매우 중요함을 확인할 수 있다.

Ⅴ. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판의 주요문제

1. 조세법률주의

1) 의의

조세법률주의는 조세의 부과는 법률의 형식에 의하여 국회의 의결을 거칠 것을 요하는 주의를 요한다.[17] 현행헌법 제59조에 의하면, 조세의 종목과 세율은 법률로 정하도록 하고 있는바, 이것은 조세법률주의를 선언하고 있는 것이다. 조세는 국가나 지방자체단체 등 공권력의 주체가 재원조달의 목적으로 과세권을 발동하여 일반국민으로부터 반대급부없이 무상으로 강제적으로 부과, 징수하는 과징금을 말한다.[18] 조세법률주의는 이러한 조세의 부과를 반드시 국민의 대표기

16) 조세조약과 법률과의 관계에 관하여는 Paul R. McDaniel and Hugh J. Ault, Introduction to United States International Taxation, Kluwer Law International, 1998, pp. 176-177 참조.
17) 김철수, 전게서, p. 1369.

관인 국회가 제정한 법률에 근거하게 하여 근대행정의 기본원리인 법치주의의 실현에 그 목적이 있음은 물론 국민의 재산권을 보호하는 동시에 법률생활의 안정을 기하려는데 그 의의가 있다.[19] 조세법률주의의 이념은 과세요건을 법률로 규정하여 국민의 재산권을 보장하고 과세요건을 명확하게 규정하여 국민생활의 법적 안정성과 예측가능성을 보장하는데 있는 것이다.[20] 조세법률주의는 행정처분으로서의 조세의 부과처분의 권한은 행정부에 속하는 것이지만 그러한 조세의 부과처분은 법률에 근거하여야 한다는 것이다. 조세법률주의에 의하면, 조세의 부과처분의 근거를 마련하는 것은 국회의 권한이다.

2) 연혁

조세에 대해서 국회가 의결하는 것이 고대영국이나 근대 프랑스의 경향이었다. 각 권리장전에는 의회에서의 과세원칙을 규정하고 있었다. 각국헌법에도 조세에 관해서는 법률로 정하게 하고 있다.[21] 조세법률주의는 영국의 마그나 카르타에서 비롯되었고, 영국의 1689년의 권리장전, 1776년의 미국 버지니아 권리장전에서 "대표없는 곳에 과세없다"는 원칙으로 확립된 이후 세계 각국에서 채택되고 있다.[22]

마그나 카르타 제12조는 "일체의 군역면제금 또는 원조금은 왕국의 일반평의회에 의하지 않고서는 부과하지 않는다. 다만 짐의 몸값을 지불하거나 또는 짐의 장남을 기사로 하기 위해 또는 짐의 장녀를 출가시키기 위해 부과되는 원조금으로서 합리적인 범위의 것일 경우에는 예외가 된다. 런던시로부터의 원조금에 대해서도 마찬가지이다"라고 규정하고 있다.[23] 마그나 카르타 제12조에 의하면 군역면제금 또는 원조금은 일반평의회에 의하여 부과되어야 한다. 영국의 1689년의 권리장전에서는 의회의 승인없이 대권의 명목으로 왕이 사용하기 위하여 돈을 부과하는 것은 불법이라고 선언되었다.[24] 1776년의 미국 버지니아 권리장전 제7

---

18) 성낙인, 제10판 헌법학, 법문사, 2010, p. 945.
19) Ibid., p. 1369.
20) 성낙인, 전게서, p. 946.
21) 김철수, 전게서, p. 1369.
22) 성낙인, 전게서, p. 945.
23) 마그나 카르타 제12조의 영어원문은 아래와 같다.
12. Scutage or aid shall be levied in our kingdom only by the common counsel of our kingdom, except for ransoming our body, for knighting our eldest son, and for once marrying our eldest daughter; and for these [purposes] only a reasonable aid shall be taken. The same provision shall hold with regard to the aids of the city of London.
24) 영국의 1689년의 권리장전 중에서 조세에 관한 부분의 영어원문은 아래와 같다.

조는 “사람들의 대표의 동의없는 권위에 의하여 법을 보류하거나 법을 집행하는 모든 권한은 사람들의 권리에 해로운 것이고, 수행되어서는 안된다”라고 규정하고 있다.[25]

3) 내용

조세법률주의는 과세요건법정주의와 과세요건명확주의를 내용으로 한다. 과세요건법정주의는 납세의무를 발생하게 하는 납세의무자, 과세물건, 과세표준, 세율 등 과세요건과 조세의 부과, 징수절차를 모두 국민의 대표기관인 국회가 제정한 법률로써 정하여야 한다는 원칙이다. 과세요건명확주의는 과세요건을 법률로 규정하였다고 하더라도 그 규정 내용이 지나치게 추상적이고 불명확하면 과세관청의 자의적인 해석과 집행을 초래할 염려가 있으므로 그 규정내용이 명확하고 일의적이어야 한다는 원칙이다.[26] 조세입법이 명확하여야 하는 것은 법률의 명확성 원칙이라는 법치주의의 요청에 의하는 것이다. 조세는 국민에게 부담을 지우는 것이기 때문에 이에 관한 입법은 특히 명확하여야 하며, 조세행정의 편의를 위하여 이를 배제하거나 약화시킬 수 없다. 조세입법에 있어서 명확성의 원칙은 조세법규의 해석과 적용에서 확대해석이나 유추를 원칙적으로 금지할 것을 요구한다. 따라서 조세법규를 유추하거나 확대해석하여 납세의무를 확대하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.[27]

헌법재판소는

[조세법률주의는 조세평등주의(헌법 제11조 제1항)와 함께 조세법의 기본원칙으로서 과세요건과 조세의 부과·징수절차는 모두 국민의 대표기관인 국회가 제

And thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, pursuant to their respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation, taking into their most serious consideration the best means for attaining the ends aforesaid, do in the first place (as their ancestors in like case have usually done) for the vindicating and asserting their ancient rights and liberties declare... That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal.

25) 1776년의 미국 버지니아 권리장전 제7조의 영어원문은 아래와 같다.

VII That all power of suspending laws, or the execution of laws, by any authority without consent of the representatives of the people is injurious to their rights and ought not to be exercised.

26) 성낙인, 전게서, pp. 946-947.

27) 정종섭, 제5판 헌법학원론, 박영사, 2010, p. 1039.

정한 법률로 이를 규정하여야 한다는 과세요건 법정주의와 그 규정내용이 지나치게 추상적이고 불명확하면 과세관청의 자의적인 해석과 집행을 초래할 염려가 있으므로 그 규정내용이 명확하고 일의적이어야 한다는 과세요건 명확주의를 그 핵심적 내용으로 하고 있는데 결국 조세법률주의의 이념은 과세요건을 법률로 명확하게 규정함으로써 국민의 재산권을 보장함과 동시에 국민의 경제생활에 법적안정성과 예측가능성을 보장함에 있는 것이다]라고 판시하고 있다.[28]

4) 기본권의 본질적 내용 침해금지와 조세법률주의의 관계

헌법 제37조 제2항에 의하면, 기본권을 제한할 때에 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다. 그런데 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙이 조세법률주의와 어떠한 관계에 있는가 하는 것이 문제된다. 즉 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙이 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 있는가 하는 것이 문제된다. 이에 대하여 형식적 조세법률주의와 실질적 조세법률주의가 대립되어 있다. 형식적 조세법률주의는 조세가 법률에만 근거하면 된다고 보는 원칙이다. 이에 대하여 실질적 조세법률주의는 법률의 형식 뿐만 아니라 세법의 목적이나 내용이 기본권보장의 헌법이념을 뒷받침하는 것이라야 한다는 원칙이다.[29]

헌법재판소는

[이 사건 법률조항은 증여세제의 본질에 반하여 증여라는 과세원인 없음에도 불구하고 증여세를 부과하는 것이어서 그 내용이 현저히 불합리하고 자의적이며 재산권보장의 헌법이념에 부합하지 않으므로 실질적 조세법률주의에 위배된다]라고 판시하고 있다.[30]

위 결정은 조세법의 내용이 재산권보장의 헌법이념에 부합하지 않으면 실질적 조세법률주의에 위배된다고 한다. 형식적 조세법률주의에 의하면, 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙은 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 없다. 따라서 조세입법이 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙은 조세법률주의로부터 나오는 것이 아니라 기본권제한입법 일반의 문제로서 헌법 제37조 제2항으로부터 나온다. 하지만 실질적 조세법률주의에 의하면, 기본권의

28) 헌재 1997.12.24. 96헌가19.
29) 김철수, 전게서, p. 1370.
30) 헌재 1997.10.30. 96헌바14.

본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙은 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 있다. 따라서 조세입법이 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙은 기본권제한입법 일반의 문제로서 헌법 제37조 제2항으로부터 나올 뿐만 아니라 조세법률주의로부터도 나오는 것이다.

헌법재판소는

[상속세법 제29조의 4 제2항은 헌법 제11조 제1항의 평등권, 제23조 제1항의 재산권, 제27조 제1항의 재판청구권을 제한하는 정도가 지나치고 불합리하여 그 본질적 내용을 침해하는 것이어서 헌법 제37조 제2항에 위배되고 그럼으로써 헌법 제38조, 제59조의 조세법률주의에 위배되는 위헌법률이라고 할 것이다]라고 판시하고 있다.[31]

위 결정의 논리구조를 보면, 문제가 되는 상속세법의 규정이 기본권의 본질적 내용을 침해함으로써 조세법률주의에도 위배된다는 것이다. 위 결정은 결국 실질적 조세법률주의에 입각한 것으로 판단된다. 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙이 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 있는 것으로 이해하는 실질적 조세법률주의는 조세법률주의의 내용을 풍부하게 하는 장점이 있다. 하지만 헌법 제37조 제2항으로도 해결할 수 있는 것을 조세법률주의로 해결하여야 할 실익이 과연 있는 것인지 여부에 관하여는 의문이 있을 수 있다. 헌법 제37조 제2항으로도 해결할 수 있는 것은 가급적 조세법률주의로 해결할 수 있는 영역에서 제외하는 것이 바람직할 수도 있다. 조세법률주의로 해결하려고 할 경우에 조세법률주의의 내용을 밝히기 위하여는 어차피 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상의 여러 원칙, 예컨대 헌법 제37조 제2항에 의존하여야 할 것이다. 사정이 이러하다면 차라리 조세법률주의로 해결하지 말고 헌법 제37조 제2항으로 직접 해결하는 것이 간편할 수도 있다. 기본권을 제한하는 입법에 관한 헌법재판에 있어서 법률주의를 명문으로 규정하고 있지 아니한 경우에는 당연히 헌법 제37조 제2항으로 해결하여야 하는데, 기본권을 제한하는 조세입법의 경우에도 비록 조세법률주의가 헌법에 명문으로 규정되고 있다 할지라도 논리의 일관성을 유지하기 위하여 조세법률주의보다는 헌법 제37조 제2항으로 해결하는 것이 바람직할 수도 있다. 또한 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙이 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 있는 것으로 이해하는 실질적 조세법률주의도 형식적 조세법률주의처럼 헌법재판에서 수행하는 기능에 한계가 있다. 실질적 조세법률주의이건 형식적 조세법률주의이건 모두 기본권조항은 아니

31) 헌재 1992.2.25. 90헌가69.

다. 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다는 원칙이 조세법률주의의 내용으로 포함될 수 있다고 하여도 조세법률주의가 기본권조항으로 변화하는 것은 아니다. 따라서 실질적 조세법률주의도 권리구제형 헌법소원심판에서는 심판청구사유로 주장할 수 없다. 왜냐하면 권리구제형 헌법소원심판은 헌법상 보장된 기본권이 침해될 것을 요건으로 하기 때문이다. 위법법률심판과 위헌심사형 헌법소원심판에 있어서 만약에 기본권을 제한하는 조세입법에 대하여 조세법률주의로 해결하려고 할 경우에 논리의 구조는 개별적인 기본권제한→ 헌법 제37조 제2항 위반→ 개별적인 기본권조항 위반→ 조세법률주의 위반이 된다.

5) 조세입법에 있어서의 위임입법

조세의 부과에 관하여는 조세법률주의가 확립되어 있다. 그런데 조세의 종목, 세율, 납세의무자, 과세대상, 과세절차에 있어 법률주의가 적용된다고 하더라도 이에 관한 세세한 것 모두를 법률로 정할 수는 없다. 조세입법에도 경제적 현상과 현실의 변화가 다양한 형태로 나타나고 그에 효과적으로 대응하기 위한 필요성이 발생하므로 이 모두를 법률로 정하면서 대응하는 것은 불가능하다. 따라서 조세입법에도 특별한 사정이 있는 경우에는 법률로 규정하여야 할 사항에 관하여 행정입법에 위임하는 것이 허용된다.[32] 조세법규처럼 기본권을 직접 제한하거나 침해할 가능성이 있는 영역에서는 구체성, 명확성의 요구가 강화되어 그 위임의 요건과 범위가 일반적인 급부행정의 영역에서보다 더 엄격하게 제한된다.[33]

1914년 이래 유럽의 모든 국가에서 생겨난 모든 역사적인 사건과 발전은 입법절차가 점차 신속하고 간단하게 되고, 법률적 규율의 성립 방법이 점점 간단하게 되고 법학이 관여하는 부문이 점차 더욱 적어지게 되었다. 항상 새롭게 더욱 더 넓은 수권이 이루어지고, 그럼으로써 입법기관은 통첩이나 명령을 법률로서의 효력을 가지는 것으로서 발포할 권한을 위임하기에 이르렀다. 통첩이나 명령이 법률을 구축하였다. 이와 같은 수권의 관행에 대한 헌법상의 의심이 도처에 존재하였으며, 또한 가까이 놓이게 되었다. 입법기관은 근대 헌법을 법철학적으로 기초지운 로크가 이미 말하였듯이 “법률은 만들지만 입법자는 만들지 못한다.”[34] 이

---

32) 정종섭, 전게서, p. 1037.

33) Ibid., p. 1037.

34) Carl Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen: Interternationaler Universit- ätsverlag, 1950, 34 S. auch in: Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materia- lien zu einer Verfassungslehre, Berlin: Duncker & Humblot, 1958, 3.Aufl., 1985, S. 386-429, 김효전 옮김, 유럽법학의 상태, 교육과학사, 1994, pp. 42-43(이 부분은 유럽법학의 상태에 나오는 것임).

말은 입법기관은 스스로 법률을 만들 뿐이며, 입법기관이 스스로 법률을 만드는 대신에 자기 대신에 법률을 만들, 그래서 그것이 입법자가 되어버리는 그러한 입법자를 만들지는 못한다는 것이다. 이러한 이유는 입법자는 이미 입법기관 자신으로 정하여졌법자가 되어버리19뷃1년의 독일 법률가 대회에서 하인리히 트리펠이 확인한 바에 의하면, 법률이 명령에 의해서 구축되는 불행@입법1차 세계대전이 시작한 직후인 1914년 8월 4일의 수권법(Ermächtigungsgesetz)과 함께 시작하였다. 트리펠은 이 날은 실로 법률이라는 것 의심이의 변천기관 자신으중요한 날이라고 하면서 그의 스승 카쉌으빈딩이 죽음 직전에 자신에게 쓴위임 통의 편지 속에서 다음과 같은 귳래서읽었다. 즉 "다음의 커다란 과뤜가 명령이 법률기관 자신으부당임 월권행위를 하는 것래서방지하는 투쟁되어"라고.[35] 사람들은 명령을 기계화신에법률이라고 평하였다. 시장질서와 경제의 국가적 지도로부터 새로운 가속도가 생겨났는데, 독일에서는 바로 이 경제의 영역에서 명령(Verordnung)의 개념과 아울러 지시(Anordnung)의 개념이 등장하였다. 지시는 입법의 가장 탄력성 있는 형식이며, 그 성립의 신속성과 공시절차의 단순성이란 점에서 명령보다 우월하다. 명령이 기계화된 법률이 된 것과 마찬가지로, 지시는 기계화된 명령으로 지정되었다.[36] 그리고 바이마르 공화국 초기의 법률과 1933년 3월 24일의 법률과 같은 수권법이 출현하게 된다.

하지만 2차 대전 이후에는 사정이 변하였다. 민주적 질서에 있어 입법기능이 의회와 불가분하게 결부되어 있다면 권력분립원칙은 이 기능을 다른 기관, 특히 집행권을 담당하고 있는 기관에 이양하는 것을 금지한다. 의회는 헌법에 의하여 의회에 배정된 기능을 집행부에 법률 혹은 법률적 효력을 가지는 법규명령을 제정할 권한을 법률로 수권함으로써 양도할 수 없다.[37] 그런데 집행부가 법률보다 하위에 있는 법규명령을 제정하도록 위임받을 수는 있다. 법규명령 제정권한의 위임은 법정립이라는 기본문제를 의회가 결정한다는 원칙에 아무런 변경도 가져오지 않는다. 기본적인 것은 의회 스스로가 결정하고 세부적인 것은 집행부에 위임하는 경우에도 의회는 헌법에 의하여 자신에게 배정된 기능을 양도하는 것은 아니다. 법규명령 제정권한의 위임은 현대사회국가에 있어서 더욱 더 필요하게 되는 세부규정에 관한 입법의 부담을 덜어 줄 수 있을 뿐만 아니라 이들 규정을 상황의 변천에 보다 신속하게 적응시킬 수 있는 가능성을 만들어 준다.[38] 법정립

35) Ibid., p. 43.
36) Ibid., pp. 46-47.
37) Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht des Bundesrepublik Deutschland, C .F. Müller, 20. Aufl.1995, S. 223 ff.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 통일 독일헌법원론, 박영사, 2001, pp. 321-322.
38) Konrad Hesse, aaO., S. 224 f.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 전게서, pp. 322-323.

을 입법권과 집행권 간에 분할하는데 있어서 전제가 되는 것은 기본적인 사항을 제정하는 것은 입법권의 수중에 남는다는 것, 집행권은 세부시행규정에 국한된다는 것 그리고 집행권이 그러한 규정을 하기 위하여는 법률적 수권을 필요로 한다는 것 등이다. 수권의 내용, 목적 그리고 범위는 법률 가운데 확정되어야 한다. 입법자에 의한 포괄적 수권은 배제된다.[39] 수권이 너무 불확정적이라서, 수권이 어떠한 경우에 또한 어떤 의도로 이용될지 그리고 수권에 의거하여 제정된 법규명령이 어떠한 내용을 가질지 더 이상 예측될 수 없는 경우에는 필요한 제한이 결여된 것이다.[40]

조세의 부과에 대하여는 조세법률주의가 헌법상 규정되어 있다고 하여도 그러한 사실이 위임입법을 부정하는 것은 아니다. 대통령의 위임입법권에 관한 현행헌법 제75조와 국무총리와 행정각부의 장의 위임입법권에 관한 현행헌법 제95조는 헌법에서 명문으로 법률주의를 규정하고 있지 않은 분야에 적용됨은 물론 헌법에서 명문으로 법률주의를 규정하고 있는 분야에도 적용된다. 현행헌법 제75조와 제95조는 헌법에서 명문으로 법률주의를 규정하고 있지 않은 분야와 헌법에서 명문으로 법률주의를 규정하고 있는 분야를 구분하고 있지는 않다. 따라서 조세법률주의가 적용되는 조세의 분야에서도 국회는 행정부에 라서 조위임세의 분 있고, 권한의 위임이 있게 되면 행정부는 위임입법의 라서 조구분게 된다. 국회가 행정부에 라서 조위임세의때 위임의 한계를 넘게 되면 현행헌법 제75조와 제95조에 대한 위반이 된다. 국회가 행정부에 라서 조위임세의때 위임의 한계를 넘게 되어도 조세법률주의 위반의 의때는 생기95조에 대한조세법률주의가 국회가 행정부에 라서 조위임세의때 지켜야 하는 위임의 되면 조포함하는 것은 아니다. 따라서 국회가 행정부에 라서 조위임세의때 지켜야 하는 위임의 되면 조위반하면 현행헌법 제75조와 제95조에 대한 위반이 될 뿐 조세법률주의 위반은 아니다. 위임의 되면때는체를 위반하는 것은 조세법률주의 위반이 아니지는 조세법이 위임의 되면 조위반하5조보면 조세법률주의의 내용인 과세요건법정주의와 과세요건명확주의에 위반하는 경우는 발생할 수 있다. 과세요건을 법률로 정하지도 않고 법률로 정한 경우에도 명확하게 정하지도 않고 포괄적으로 위임을 하면 위임의 원칙에 대한 위반 뿐만 아니라 과세요건법정주의와 과세요건명확주의에 대한 위반도 성립한다. 조세법이 과세요건을 법률로 명확하게 정한 상태에서 위임의 원칙을 위반하거나 과세요건과 관계가 없는 사항에 관하여 위임의 원칙을 위반하면 과세요건법정주의와 과세요건명확주의에 대한 위반의 문제는 발생하지 않는다.

---

39) Konrad Hesse, aaO., S. 224 ff.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 전게서, p. 323.
40) Konrad Hesse, aaO., S. 225 f.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 전게서, pp. 323-324.

헌법재판소는

[이 사건 법률조항호의 규정은 국민의 납세의무의 범위와 직접적인 관계를 가지고 있는 중요한 사항을 하위법규인 대통령령에 전적으로 일임함으로써 포괄적으로 위임하였으므로 조세법률주의와 위임입법의 한계에 관한 헌법 제59조, 제75조의 규정을 위반하였다]라고 판시하고 있다.[41]

위 결정은 위임입법의 한계에 대한 위반 뿐만 아니라 조세법률주의에 대한 위반도 함께 인정하고 있는데, 그 이유는 문제가 되는 규정이 납세의무의 범위와 직접적인 관계를 가지고 있기 때문이다. 납세의무의 범위와 직접적인 관계를 가지고 있는 사항을 포괄적으로 위임하게 되면 과세요건법정주의와 과세요건명확주의에 대한 위반도 아울러 성립하게 된다.

헌법재판소는

[이 사건 법률조항은 과세요건 중 가장 중요한 과세대상 내지 과세물건을 법정하지 않은 채 이를 포괄적으로 하위법규인 대통령령에 위임한 것으로서 과세당국의 행정편의적인 규정이라 아니할 수 없다. 따라서 이는 과세요건 법정주의를 핵심내용으로 하는 조세법률주의에 정면으로 위반될 뿐만 아니라 위임입법의 한계를 일탈한 것임이 분명하다]라고 판시하고 있다.[42]

위 결정은 위임입법의 한계에 대한 위반 뿐만 아니라 조세법률주의에 대한 위반도 함께 인정하고 있는데, 그 이유는 문제가 되는 규정이 과세대상 내지 과세물건에 관한 것이기 때문이다. 과세대상 내지 과세물건에 관한 사항을 포괄적으로 위임하게 되면 과세요건법정주의와 과세요건명확주의에 대한 위반도 아울러 성립하게 된다.

국회가 상속세 및 증여세법을 통하여 행정부에 권한을 위임할 때 위임의 한계를 넘어 위헌으로 되는 것 중에는 국회의 부주의 또는 무성의에서 비롯된 것이 적지 않다. 국회가 제대로 주의를 하고 성의를 가지고 있다면 위임의 한계 위반은 그리 많이 발생하지 않을 것이다. 국회가 행정부에 권한을 위임할 때에는 위임의 원칙을 충실하게 준수함으로써 권한의 위임이 위헌으로 되는 것을 방지하여야 한다. 법률에서 행정부에 위임을 할 때 위임사항을 구체적으로 명확하게 정하는 일이 그리 어려운 일은 아니다. 위임사항을 구체적으로 명확하게 정하게 되

41) 헌재 1998.4.30. 96헌바78.
42) 헌재 1998.4.30. 95헌바55.

면 위헌의 문제는 발생하지 않을 것이다.

2. 기본권의 제한

1) 기본권의 구속력

가권력은 기본권에 구속된다. 입법권을 기본권에 구속시키는 것은 과거에는 의견이 분분하였으나 현재에는 입법권도 기본권에 구속된다. 입법자를 기본권에 구속시키는 것은 중대한 의의를 갖는 것이다. 즉 기본권은 입법자의 결정의 자유를 제한하고 있는 것이다. 기본권의 내용에 부합되는 입법을 할 임무가 주어지는 한 기본권은 단지 입법자의 재량에 따라 실현되는 프로그램이 아니다. 국가권력의 기본권에의 구속은 법률이 기본권에 반하는가를 사법적으로 심사할 전제조건인 것이다. 기본권의 보장은 모든 법원의 임무이며 그 최종적 보장의 책임은 광범한 권한을 갖고 있는 헌법재판소의 임무이다.[43] 입법은 합헌적 질서에 구속되므로 기본권 및 그 배후의 여러 법원리들, 무엇보다도 인간존엄의 존중의 원리에 구속된다. 실질적 법치국가 개념은 19세기의 형식적 법치국가 개념의 가장 중요한 요소들, 즉 행정의 법률에의 엄격한 기속과 모든 행정행위의 적법성에 대한 행정법원의 심사라는 요소를 포함하나 나아가 기본적 법원리와 이를 형상화하는 기본권조항에 입법자가 구속되는 것 및 이러한 구속 여부를 헌법재판소에 의하여 감시하는 것이 이에 부가된다.[44]

2) 기본권 제한의 한계

기본권은 국가권력을 구속하지만 일정한 경우 기본권은 제한을 받게 된다. 그러나 기본권의 제한에는 한계가 있다. 기본권을 제한하는 법률이 한계를 벗어나게 되면 위헌이 된다. 법률의 유보하에서 보장되고 있는 기본권이라고 해도 헌법질서에 있어서는 입법자의 자의적 처분에 맡겨져 있지 않다. 기본권을 제한할 때 기본권의 본질적 내용을 침해하여서는 안된다. 기본권을 제한할 수 있는 권한을 부여하는 것은 결코 기본권의 보장으로부터 분리되어서는 안되며 그와 같은 권한의 부여는 오히려 항상 기본권의 의의라는 관점에서 보아야 한다.[45] 기본권적

---

43) Konrad Hesse, Bestand und Bedeutung der Grundrechte, 계희열 역, 헌법의 기초이론, 삼영사, 1985, p. 181.

44) Karl Larenz, Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik, München: C. H. Beck, 1979, 양창수 역, 정당한 법의 원리, 박영사, 1986, p. 144.

45) Ibid., p. 189.

자유와 그 밖의 법익을 보호하는 규정들이 그 내용상 미치는 범위에 있어서 상호 중복되거나 충돌하는 경우 기본권 제한은 원칙적으로 실제적 조화의 실현이다. 실제적 조화의 과제는 기본권과 기본권을 제한하는 법익간의 비례적 정서를 요청한다. 헌법적 제한 또는 법률유보에 근거한 제한을 해석할 때 중요한 것은 기본권과 그 제한하는 법익이 최적의 실효성을 얻도록 하는 것이다. 기본권은 법률유보 하에 있는 경우에도 헌법질서의 본질적 구성부분에 속하므로 결코 하나의 기본권적 보장으로부터 공동체의 생활에 있어서 갖는 그 실효성을 필요 이상으로 혹은 완전히 박탈해 버리는 방식으로 비례관계규정이 이루어져서는 안된다.[46] 그러므로 기본권의 제한은 기본권 제한이 행해지는 목적인 법익보호를 실현하는데에 적합하여야 한다. 기본권의 제한은 법익보호를 위하여 필요한 것이어야 한다. 보다 약한 제한수단으로 충분할 경우는 이에 부합되지 않는다. 기본권의 제한은 비례성이 있어야 한다. 즉 기본권의 중요성 및 의의와 적정한 관계에 있어야 한다.[47] 기본권의 제한을 비례의 원칙 하에 둠으로써 기본권의 제한가능성은 결정적으로 축소된다.[48] 상이한 기본권적 지위들이 충돌하는 경우와 같이 특별한 경우에 있어서는 비례적 정서의 테두리 내에서 결과적으로 기본권을 완전히 후퇴시키지 않을 수 없다. 하지만 이것은 단순히 근거없는 이익형량의 방법으로는 이루어질 수 없는 그 이상의 법적 근거 제시를 필요로 한다.[49]

헌법재판소는 기본권조항에 대한 위반 여부를 판단할 경우 심판대상조문이 기본권을 제한하고 있는지 여부를 결정한 다음 이러한 제한입법이 헌법 제37조 제2항에 의한 기본권 제한의 요건을 갖추었는지 여부를 다시 결정하고 있다. 이러한 논리구조는 헌법의 규정에 충실한 것으로 보인다. 이러한 논리구조에서는 기본권 제한입법이 제한의 요건을 갖추지 못하였을 경우 헌법 제37조 제2항에 대한 위반이 되고 그 결과 개별적인 기본권조항도 위반한 것으로 된다.

헌법재판소는

---

46) Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht des Bundesrepublik Deutschland, C .F. Müller, 20. Aufl.1995, S. 142 f.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 통일 독일헌법원론, 박영사, 2001, p. 203.

47) Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht des Bundesrepublik Deutschland, C .F. Müller, 20. Aufl.1995, S. 142 f.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 통일 독일헌법원론, 박영사, 2001, pp. 203-204.

48) Konrad Hesse, Bestand und Bedeutung der Grundrechte, 계희열 역, 헌법의 기초이론, 삼영사, 1985, p. 189.

49) Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht des Bundesrepublik Deutschland, C .F. Müller, 20. Aufl.1995, S. 142 ff.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 통일 독일헌법원론, 박영사, 2001, p. 204.

[헌법상 보장되어 있는 평등권, 재산권, 재판청구권 등 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되었다고 볼 수는 없을 것이다. 따라서 이 법 제7조의 2 제1항을 간주규정으로 본다면 헌법 제11조 제1항, 제27조 제1항에 위반될 뿐만 아니라]라고 판시하고 있다.[50]

위 결정은 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 비례관계가 유지되고 있는지 여부를 판단한 다음 비례관계가 유지되고 있지 않으므로 헌법상의 개별적인 기본권조항에 위반된다고 하고 있다. 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 비례관계가 유지되고 있는지 여부를 판단하는 것은 헌법 제37조 제2항에 의한 기본권 제한의 요건과 관련된 것이다. 위 결정은 결국 헌법 제37조 제2항에 의한 기본권 제한의 요건을 갖추지 못하고 있기 때문에 헌법상의 개별적인 기본권조항에 위반된다고 하고 있다.

헌법재판소는

[증여세를 물리면서 그에 대하여 재판청구마저도 못하게 하는 것이어서 이는 헌법 제11조 제1항의 평등권, 제23조 제1항의 재산권, 제27조 제1항의재판청구권 등 여러 기본권을 제한 내지 박탈하는 것이라고 할 수 있다. 물론 이러한 평등권, 재산권, 재판청구권도 헌법 제37조 제2항에 의하여 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에는 권리의 본질적 내용을 침해하지 아니하는 한도에서 법률로써 제한될 수는 있는 것이다. 따라서 상속세법 제29조의4 제2항의 규정이 헌법 제37조 제2항에 의한 기본권제한입법의 요건을 갖추었는지를 살펴볼 필요가 있다...배우자 또는 직계존·비속간의 부담부증여인 것이 아무리 명백한 경우라도 위 법률조항 단서의 경우에 해당되지 아니하면 채무인수가 부인되고 억울한 조세부과에 대하여 쟁송의 길마저 막아버리는 상속세법 제29조의4 제2항의 규정은 결국 실지조사와 쟁송의 번거로움을 피하고 편리한 세금징수의 방법만을 강구한 나머지 조세형평이나 국민의 기본권 보장은 도외시한 채 오직 조세행정의 편의만을 위주로 하여 제정된 매우 불합리한 법률이고 기본권 경시와 행정편의주의 및 획일주의의 정도가 지나쳐 평등권, 재산권, 재판청구권 등 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권사이에 합리적인 비례관계가 유지되었다고 볼 수 없다. 그리하여 상속세법 제29조의4 제2항은 헌법 제11조 제1항의 평등권, 제23조 제1항의 재산권, 제27조 제1항의 재판청구권을 제한하는 정도가 지나치고 불합리하여 그 본질적 내용을 침해하는 것이어서 헌법 제37조 제2항에 위배되고]라고 판시하고 있다.[51]

---

50) 헌재 1994.6.30. 93헌바9.

위 결정은 헌법상의 개별적인 여러 기본권을 제한 내지 박탈하는 것이라고 판단한 다음 헌법 제37조 제2항에 의한 기본권제한입법의 요건을 갖추었는지를 살펴 보고, 기본권제한입법의 요건을 갖추지 못하여 헌법 제37조 제2항에 위배된다고 판단하고 있다. 위 결정은 기본권제한입법의 요건과 관련하여 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권사이에 합리적인 비례관계가 유지되었지 여부를 판단하고 있다. 그리고 위 결정은 합리적인 비례관계가 유지되지 못하고 있기 때문에 헌법 제11조 제1항의 평등권, 제23조 제1항의 재산권, 제27조 제1항의 재판청구권의 본질적 내용을 침해하는 것이라고 하고 있다. 위 결정은 기본권의 본질적 내용을 침해하면 헌법 제37조 제2항에 위배된다고 하고 있다.

3) 편의주의

국회는 입법의 방식, 내용, 형식의 결정에 있어서 일정한 형성의 자유를 가진다. 헌법재판소는 광범한 입법형성권의 자유를 인정하고 있다. 조세의 부과대상이 되는 과세대상에 대해서 입법형성의 자유를 인정하고 있으며, 입법의 완결성을 요구할 수 없다. 하지만 입법형성권에도 한계가 있다. 입법형성의 자유는 입법재량과 밀접히 관련되어 있다. 조세의 특수성 또는 입법기술상의 제약성 때문에 조세입법의 재량성이 인정된다. 또한 국회가 입법에 있어서 판단의 여지가 있는 경우 재량을 인정한다. 이에는 넓정하인정하는 경우와 좁정하인정하는 경우가 있다. 국회의 입법재량권은 완전한 자유재량이 아니며, 헌법에 따른 입법재량의 한계가 인정되고 있다. 헌법재판소는 입법재량을 인정하면서도 기속재량이 있음을 밝히고 있다.[52] 국회는 입법형성의 자유 또는 입법재량을 가지고 있지만 이에는 일정한 한계가 있다. 이와 관련하여 편의주의의 문제가 있다.

헌법재판소는

[억울한 조세부과에 대하여 쟁송의 길마저 막아 버리는 것이 될 뿐만 아니라 실지조사와 쟁송의 번거로움을 피하고 편리한 세금징수의 방법만을 강구한 나머지 행정편의주의 및 획일주의의 정도가 지나치다고 아니할 수 없어 헌법상 보장되어 있는 평등권, 재산권, 재판청구권 등 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되었다고 볼 수는

51) 헌재 1992.2.25. 90헌가69.
52) 김철수, 전게서, pp. 1323-1325.

없을 것이다]라고 판시하고 있다.[53]

위 결정은 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되었는지 여부를 판단하는데 있어서 문제의 규정이 편의주의적인 규정인가 아닌가를 고려하고 있다. 문제의 규정이 오로지 편의주의적인 규정이라면 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되지 못하고 있다고 볼 여지가 큰 것이다.

헌법재판소는

[억울한 조세부과에 대하여 쟁송의 길마저 막아버리는 상속세법 제29조의4 제2항의 규정은 결국 실지조사와 쟁송의 번거로움을 피하고 편리한 세금징수의 방법만을 강구한 나머지 조세형평이나 국민의 기본권 보장은 도외시한 채 오직 조세행정의 편의만을 위주로 하여 제정된 매우 불합리한 법률이고 기본권 경시와 행정편의주의 및 획일주의의 정도가 지나쳐 평등권, 재산권, 재판청구권 등 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권사이에 합리적인 비례관계가 유지되었다고 볼 수 없다]라고 판시하고 있다.

위 결정 또한 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되었는지 여부를 판단하는데 있어서 문제의 규정이 편의주의적인 규정인가 아닌가를 고려하고 있다. 위 결정에 의하면, 조세형평이나 국민의 기본권 보장은 도외시한 채 오직 조세행정의 편의만을 위주로 하여 제정된 매우 불합리한 법률이고 기본권 경시와 행정편의주의 및 획일주의의 정도가 지나치면 중대한 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되었다고 볼 수 없는 것이다. 헌법재판소는 편의주의적인 동기가 농후한 규정에 대하여 부정적인 평가를 하고 있다.

상속세 및 증여세법에 있어서 편의주의에 치우친 나머지 입법형성의 자유 또는 입법재량의 한계를 넘어 위헌문제를 야기하는 경우가 적지 않다. 조세입법에 있어서 행정관청의 편의를 완전히 무시할 수는 없는 것이지만 그러한 편의를 도모함으로써 기본권이 심하게 제한되는 결과가 야기된다면 편의주의를 통하여 얻어지는 과세관청의 편의와 희생되는 기본권을 비교형량하여 합리적인 비례관계가 유지되고 있는지 여부를 판단하여야 한다. 만약에 기본권을 제한함으로써 얻어지는 공익과 제한되는 기본권 사이에 합리적인 비례관계가 유지되지 못하고

53) 헌재, 1994.6.30. 93헌가9.

있다면 기본권 제한입법의 한계를 일탈한 것이고, 입법형성의 자유 또는 입법재량의 한계를 일탈한 것이다.

4) 정의의 원칙

헌재 1998.5.28. 96헌마151 사건의 청구인은 심판청구사유로서 정의에 대한 위반을 주장하고 있다. 청구인은 "이 사건에서는 신고 여부에 따라 재산평가차이가 엄청나고 또한 만약 1991년 이후에 상속이 개시되었다면 신고 여부와 관계없이 개별공시지가로 평가되나, 그 대신 신법(1990. 12. 31. 개정된 것)에 따르면 각종 공제의 현실화(특히 배우자의 재산형성 기여도를 감안한 배우자공제), 세율인하 등이 적용되는 것이므로, 개별공시지가가 공고된 1990. 8. 30.부터 1990. 12. 31. 사이에 상속이 개시된 무신고 또는 신고누락재산에 대해서만 법의 사각지대가 생기게 되고, 이는 정의와 형평에 위반된다"라고 주장하고 있다. 이 사건 심판청구는 부적합하여 각하되었기 때문에 이 사건에서는 청구인이 주장하는 정의와 형평에의 위반 여부와 만약에 심판대상조문이 정의와 형평에 위반되었을 경우의 헌법상의 효력 여부에 관한 판단은 이루어지지 않았다. 그런데 정의의 원칙은 과연 헌법재판에서 위헌심사의 기준이 될 수 있는가 하는 문제가 대두된다.

오늘날 실정헌법에는 정의의 원칙이 거의 다 포함되어 있으므로 별 문제가 없으나 실정헌법규범이 정의의 원칙에 위배되는 경우 정의의 원칙도 위헌법률심판의 기준이 될 수 있다는 견해가 있다.[54] 이에 대하여 정의의 관념이 입법에 있어 존중되어야 함은 물론이지만 위헌법률심판에서도 심판의 기준이 될 수 있는가는 의문이라는 견해도 있다.

정의의 원칙의 내용은 분명하지 않다. 정의가 평등을 의미할 수도 있다. 그런데 평등 자체가 여러 가지 의미를 가질 수 있다. 평등은 그 표준에 따라 절대적 평등도 될 수 있고, 상대적 평등도 될 수 있다. 이 두 구별을 결합한 것이 유명한 아리스토텔레스의 정의론이다.[55] 아리스토텔레스에 의하면, 평등에는 산술적 평등(numerical equality)과 비례적 평등(proportional equality)이 있고 양자 사이에는 결정적인 차이가 있다. 산술적 평등이란 모든 사람을 하나의 단위로서 다른 사람과 동등하게 취급한다는 것이다. 이것은 모든 시민은 법 앞에서 평등하다고 말할 때의 평등을 의미한다. 비례적 평등은 각인에게 그의 능력과 업적 등등에 따라서 그가 가질 자격이 있는 것을 주는 것이다. 그리고 아리스토텔레스는 정의

54) 김철수, 전게서, p. 1678.

55) Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8.Aufl.1973, 최종고 번역, 제3판 법철학, 삼영사, 2007, pp. 64-65.

를 배분적 정의(distributive justice)와 교정적 정의(corrective justice)로 구별하였다. 전자는 공법에서 후자는 민법과 형법에서 작용한다. 양자는 모두 평등의 문제에 속하는 것이다.배분적 정의는 행정의 영역이고, 교정적 정의는 사법의 영역이다. 배분적 정의에서 중요한 것은 평등한 보상은 평등한 성과에 따라야 한다는 것이다. 배분적 정의는 명예, 부 그리고 공동체의 성원에 의해서 공유될 수 있는 기타의 선의 배분과 관련되어 있다. 재산과 다른 가치 있는 소유물을 시민의 고유한 장점에 따라서 배분한다는 것이다. 정당한 배분이란 시민들의 덕과 그들의 공동체에 대한 가치에 상응하는 배분일 것이다. 교정적 정의에서 중요한 것은 예컨대 계약의 위반에 의해서 야기된 불평등이 교정되고 제거되어야 한다는 것이다. 교정적 정의는 잘못을 바로잡는 것이다. 만약 계약이 파기되거나 불법행위가 행하여진다면 교정적 정의는 위법행위를 당한 당사자에게 적절한 보상을 해주려고 할 것이며 범죄가 행해졌을 때는 적절한 형벌이 범법자에게 할당될 것이다. 여기서의 정의란 두 개의 극단적인 부정의 사이의 중용인 것이다. 부정의가 행해질 때는 기존의 평등이 교란되고 있는 것이다. 이러한 평등을 재확립한다는 것 또는 균형을 되찾는다고 하는 것이 교정적 정의의 과제인 것이다.[56] 배분적 정의가 정의의 원형이다. 이 정의 속에서 법개념이 방향지워지지 않으면 아니될 정의의 개념을 발견할 것이다.[57]

정의의 원칙이 헌법에 규정된 경우도 있는데, 바이마르 헌법에는 정의의 원칙에 관한 규정이 있다. 바이마르헌법 제151조(경제상의 자유보장) 제1항은 “경제생활의 질서는 각자로 하여금 인간의 가치에 타당한 생활을 하게 하는 것을 목적으로 하고 정의의 원칙에 적합하여야 한다. 각자의 경제상의 자유는 이 한계 내에서 보장된다”라고 규정하고 있다.[58] 위 제151조 제1항에 의하면 바이마르공화국의 경제생활의 질서는 정의의 원칙에 적합하여야 하는데, 이것은 정의로운 경제생활의 질서를 바이마르공화국이 표방한 것이다. 여기에서 정의의 원칙이 무엇인가 하는 해석상의 문제가 제기된다. 각자의 경제상의 자유는 정의의 원칙에 적합한 경제생활의 질서라는 한계 내에서 보장된다. 경제상의 자유의 보장의 한계는 바로 정의의 원칙이다. 정의의 원칙이 경제상의 자유의 한계인 것이다. 따라서 경제상의 자유는 정의의 원칙에 부합하여야 한다.

---

56) Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, The University of Chicago Press, 1963, 이병훈 역, 법철학, 교육과학사, 1996, pp. 44-46.

57) 최종고 번역, 전게서, p. 65.

58) 바이마르헌법 제151조(경제상의 자유보장) 제1항의 원문은 아래와 같다.
Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsatzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewahrleistung eines menschenwurdigen Daseins fur alle entsprechen.In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu sichern.

정의의 원칙이 헌법에 규정되어 있는 경우에는 위헌심사의 기준이 될 수 있을 것이다. 그런데 정의의 원칙이 헌법에 규정되어 있지 않은 경우가 문제이다. 이 경우 정의의 원칙이 위헌심사의 기준이 될 수 있는가 하는 문제의 해결에는 시간이 좀더 필요할 것이다.

5) 이중과세

조세법에 있어서 이중과세의 문제는 논란이 분분하다. 이중과세의 문제는 조세학 또는 조세법의 이론과 밀접한 관련이 있으며, 앞으로 계속적인 연구가 필요한 분야이다. 헌재 1997.12.24. 96헌가19 사건에서는 이중과세의 문제가 다루어지고 있다. 위 사건의 제청법원의 제청결정이유는 "상속재산의 가액에 합산되는 증여재산을 상속개시시점을 기준으로 평가하여 과세하면, 당해 재산의 증여시점과 상속개시시점 사이의 가액 증가분에 대하여 양도소득세와 상속세가 이중과세될 수 있다. 즉 어떤 증여재산이 상속재산 가액에 합산되어 상속세가 과세되는 경우, 그 재산의 증여시점과 상속개시시점 사이의 가액 증가분에 대하여는 상속세 명목으로 일단 과세가 되었음에도 차후 그 증여재산을 타에 양도하는 경우 그 증여재산의 소유자는 증여시점과 양도시점 사이의 가액 증가분(양도차익) 전체에 대하여 다시 양도소득세를 부담하게 되므로 당해 재산의 증여시점과 상속개시시점 사이의 가액증가분에 대하여는 양도소득세와 상속세가 이중과세되는 결과에 이른다. 수증자가 부담부증여를 받아 증여자의 채무를 인수하는 경우에 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분은 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보아 증여자는 양도소득세 납부의무를 부담하게 되고(1994. 12. 22. 법률 제4803호로 전문개정되기 전의 구 소득세법 제4조 제3항 후단이른다문개정 보후의 소득세법 제88조 제1항 후단), 수증자는 전체 증여재산가액에서 인수한 채무액을 공제한 순증여재산 가액에 대하여만 증여세 납부의무를 부담하게 된다. 그런데 부담부증여를 받은 재산이 상속재산의 가액에 합산되는 경우에는 증여재산 전체의 가액이 상속재산의 가액에 합산되는데 반하여, 순증여재산 가액만을 대상으로 하여 산정한 증여세액만이 상속세 산출세액에서 공제될 뿐이므로 증여재산의 전체가액 중 수증자가 인수한 채무액에 상당하는 부분은 양도소득세와 상속세가 이중으로 과세되는 결과에 이른다"는 것이다.

이에 대하여 헌법재판소는

[상속개시전 일정기간의 증여재산의 가액을 상속재산의 가액에 가산하면서 이 사건 조항에 의하여 증여재산의 가액을 증여 당시의 가액에 의하지 않고 상속

당시의 가액에 의하여 상속세를 과세하면 재산처분행위인 증여 당시 그로 인하여 부담할 세액을 예측할 수 없어 국민의 경제생활에 법적안정성을 침해할 뿐만 아니라 그 재산의 증여 당시와 상속 당시 사이에 가액의 증가가 있는 경우 그 가액증가분에 대하여 수증자는 상속세를 부담하는 외에 그 증여재산을 양도할 때 다시 양도소득세를 이중으로 부담하게 되는 결과에 이르게 되므로 이와 같은 점에서도 이 사건 법률조항은 조세법률주의에 위반된다]라고 판시하고 있다.

위 결정은 상속세와 양도소득세를 모두 부담하게 되는 것은 이중과세이며, 이중과세가 이루어지면 조세법률주의에 위반된다고 한다. 위 결정은 이중과세 금지의 원칙은 조세법률주의에 포함된다고 보고 있는 것이다. 위 결정은 이중과세 금지의 원칙과 조세법률주의가 연결되는 논리를 실질적 조세법률주의에서 찾고 있다.

위 결정은

[법치주의는 국민의 권리·의무에 관한 사항을 법률로써 정해야 한다는 형식적 법치주의에 그치는 것이 아니라 그 법률의 목적과 내용 또한 기본권 보장의 헌법이념에 부합되어야 한다는 실질적 적법절차를 요구하는 법치주의를 의미하며, 헌법 제38조, 제59조가 선언하는 조세법률주의도 이러한 실질적 적법절차가 지배하는 법치주의를 뜻하므로, 비록 과세요건이 법률로 명확히 정해진 것일지라도 그것만으로는 충분한 것은 아니고 조세법의 목적이나 내용이 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상 요구되는 제원칙에 합치되어야 한다]라고 판시하고 있다.

위 결정은 조세법률주의는 실질적 조세법률주의이며, 따라서 조세법의 목적이나 내용이 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상 요구되는 제원칙에 합치되어야 한다고 하고 있다. 그런데 위 결정은 이중과세는 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상 요구되는 제원칙에 합치되지 않는다고 한다. 따라서 이중과세는 실질적 조세법률주의에 위반된다는 것이다. 위 결정은 이중과세를 위헌으로 만드는 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상 요구되는 제원칙으로 헌법 제37조 제2항(과잉입법금지원칙)을 들고 있다. 이중과세는 헌법 제37조 제2항(과잉입법금지원칙) 위반이라는 것이다. 그리고 헌법 제37조 제2항(과잉입법금지원칙) 위반은 조세법률주의 위반도 된다는 것이다. 그리하여 위 결정은 결론에서 이 사건 법률조항은 헌법 제23조 제1항(재산권보장), 제37조 제2항(과잉입법금지원칙), 제38조, 제59조(조세법률주의)에 위반된다고 하고 있다.

위 결정은 이중과세가 헌법상 금지되는 것으로 판단하고 있다. 어떠한 조세가 이중과세에 해당하면 헌법 위반이 된다. 그런데 어떠한 조세가 이중과세에 해당하는지 여부를 판단하는 일이 쉬운 일은 아니다. 이중과세에 해당하는지 여부의 판단기준이 분명하지 않기 때문이다.

6) 조세평등주의

(1) 의의

조세평등주의는 국가는 조세입법을 함에 있어서 조세의 부담이 공평하게 국민들 사이에 배분되도록 하여야 한다는 것을 말한다. 조세평등주의는 조세법률주의와 함께 헌법상에 기초를 두는 조세법의 기본원칙이다. 조세평등주의는 헌법 제11조의 평등의 원칙 또는 차별금지의 원칙의 조세법적 표현이라고 할 수 있다.[59] 조세평등주의는 헌법상 평등의 원칙의 당연한 구현이다. 조세평등주의에 의하면 조세의 부과징수에 있어서 합리적인 이유없이 특정의 납세의무자를 불리하게 차별하거나 우대하는 것은 헌법상 허용되지 아니한다.

평등의 원칙의 내용은 자의의 금지로서 또는 평등 내지 불평등 취급의 근거가 되는 기준을 사리에 맞지 않게 결정하는 것을 금지하는 것이다. 평등의 원칙은 소극적으로 평등 또는 불평등 취급의 기준들을 자의적으로 정하는 것을 금지할 뿐만 아니라 적극적으로 정의의 요청에 따라 본질적인 기준을 선택할 것을 명령한다. 정의는 주어져 있는 어떤 것이 아니라 인간이 달성하지 못할 수도 있으나 항상 추구해야만 하는 과제로 부과된 어떤 것이다. 바로 여기에서 평등의 원칙의 그 특별한 규범적 기능이 나타난다. 평등의 원칙은 국가권력에게 각자에게 그의 것을 주라는 첫 번째이며 가장 중요한 과제를 부여한다. 평등의 원칙은 이러한 정의의 원리를 헌법적으로 실정화한 것으로서 모든 국가활동이 정향해야 하고 동시에 그에 지향해야 하는 목표를 제시한다.[60] 아리스토텔레스는 니코마코스 윤리학(The Nicomac-

hean Ethics)에서 정의를 논하면서 다음과 같이 쓰고 있다. 만약에 사람들이 평등하지 않다면, 그들은 평등한 몫을 가지지 않을 것이다. 그리고 싸움과 불만이 발생하는 것은 바로 평등한 사람들이 불평등한 몫을 가지거나 배정되었거나

59) 성낙인, 전게서, pp. 949-950.

60) Konrad Hesse, Gleichheit und Freiheit als Grundprinzipien heutiger staatlicher Ordnung in: Individiuum und Kollektiv, Freiburger Dies Universitatis Bd.9, S. 79 ff., 계희열 역, 헌법의 기초이론, 삼영사, 1985, pp. 222-223.

또는 평등하지 않은 사람들이 평등한 몫을 가지거나 배정되었을 때이다.[61] 이를 요약하면, 같은 사람은 같게, 다른 사람은 다르게 대우하라는 것이다. 이를 다시 사람 외에 확장하면 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 취급하라는 것이다. 아리스토텔레스는 사람들에게 하는 분배의 문제에 관하여 위와 같은 논리를 전개하였지만 이것이 사람들에게 하는 분배의 문제에 국한하여 적용되는 것은 아니다. 사람들에게 하는 분배의 문제에 위 논리를 적용하면 그 때는 분배에 있어서의 정의의 기준이 되지만 사람들에게 하는 분배의 문제 이외의 문제에 위 논리를 적용하면 그 때는 그 문제의 해결에 있어서의 기준이 되는 것이다.

에리히 카우프만은 1927년 바이마르 헌법의 평등조항에 관한 연설에서 동조항을 초실정적으로 효력을 가지는 하나의 법원리로 이해하고, 따라서 그것은 무엇보다도 그리고 1차적으로 성문법을 만드는 직책을 가지는 입법자에 대하여 적용되며, 그는 그 법제정에 있어서 이 법원리를 위반하여서는 아니된다고 하였다. 이어서 당시는 초문인 명제가 제기된다. "일정한 최고의 법원리을 위반하지 않는 경우에만 법률은 법을 창조하는 것이다."[62]

이러한 평등의 원칙이 조세법의 분야에서 구현된 것이 조세평등주의이다. 조세평등주의는 조세부담의 공평원리를 말한다. 조세부담의 공평원리는 조세를 부담함에 있어서 모든 납세자는 공정하고 평등하게 대우되어야 한다는 것을 말한다. 국가가 조세라는 부담을 국민에게 부과할 때 이러한 부담은 공평하게 이루어져야 한다. 공평부담은 헌법의 법치주의와 평등조항에 따라 조세를 포함한 모든 일반적 부담행위에 공통하여 적용되는 것이기도 하다.[63]

(2) 내용

조세의 공평이란 구체적으로 어떠한 경우를 의미하는가에 대해서는 의견이 나누어져 있다. 국가로부터 제공받은 이익에 비례하여 조세를 부담하는 것이 공평하다는 이익설의 관점과 조세를 부담할 수 있는 경제적 지불능력에 비례하여 부담하는 것이 공평하다는 능력설의 관점이 있다.

이익설의 관점은 재정의 수입과 지출의 양면을 모두 고려하는 점은 있으나 개

---

61) Aristotle, The Nicomachean Ethics, Book V, Penguin Books, 2004, p. 119(위 책은 J. A. K. Thomson에 의하여 1953년에 번역된 것임). 위 문장의 위 책에서의 영문은 아래와 같다.
for if the persons are not equal, they will not have equal shares; and it is when equals have or are assigned unequal shares, or people who are not equal, equal shares, that quarrels and complaints break out.

62) 양창수 역, 전게서, p. 143.

63) 정종섭, 전게서, p. 1043.

별납세자가 여러 이익들에 대하여 자기 선호를 자발적으로 표시하지 않으려고 하는 점과 국가가 국민 모두에게 일반적으로 제공하는 이익에서 각자 얼마만큼 이익을 받는지를 측정할 수 없다는 점에서 이론상의 한계를 가지고 있다.[64] 이익원칙에 따르면 각 납세자가 공공서비스로부터 받는 이익에 상응하여 조세를 부담할 때 세제는 가장 공평한 것이 된다. 따라서 공평의 척도가 되는 지표는 각 납세자가 공공서비스로부터 받은 이익이 된다. 정부활동의 본질이 국민의 생명과 재산을 보호하는 데 있다면 조세는 국가의 보호를 받는 수익자가 향수하는 이익에 따라 배분되어야 한다고 생각한다. 그런데 이익원칙에 의한 과세는 공정이라는 조세정의의 기준을 경제적 관점에서 합리화시킬 수 있으나 이익원칙은 실천적 기준이 될 수는 없다.[65]

능력설의 관점은 소득의 분배에는 기여하지만 재정의 수입면에만 치중하고 있다는 점과 담세력을 정확히 측정할 수 있는 기준을 도출하기 어렵다는 점에서 이론상의 약점을 가지고 있다.[66] 능력설에 의하면 조세의 부담은 국가의 공공서비스의 급부와 하등의 관련이 없고, 과세는 지급능력에 따라 행하여진다. 능력원칙을 조세제도의 구성과 평가를 위한 실천기준으로 이용하기 위해서는 능력 또는 경제적 후생을 측정할 수 있는 지표가 필요한데 종전부터 그러한 목적약점을 해 소득, 부 및 지출이 이용되어 을 정확소득의 개념도 여러 가지로 규정할 수 있으나 일반적으로 는 기간중확소비와 저축약점을하여 획득한 수입액으로 정의할 수 있 정확현대에 있어서는 소득이 생계수준을 나타내고, 조세부담능력을 표시하는 가장 적생각되고 있다. 그러나 일 점에소득에 의하여 영위할 수 있는 생활수준은 소득의 절대액만이 점라 그 밖의 여러 가지 조건에 의하여 규정된다. 즉 가족수, 자녀의 수 혹은 지출구성 등이 그면 조세 그러므로 소득만을 가지고서 지급능력을 측정할 수는 없는 롼을 표시개인의 경제적 후생 혹은 지급능력은 소득만이 점라 축적타내부에 의해서도 영향을 받는 표시원칙적으로 재산을 갖고 있는 좐할 재산을 갖지 못하는 자가 동일할 수는 없조세 그러므로 소득과 재산은 모두 지급능력을 표시하는 지표라고 생각하는 것이 더욱 공정한 것이조세 그 중에서 소득이 더 소망스러운 지표적타는 하지만 재산도 생활수준을 °절대는 요인이라는 점에서 소득기준은 재산에 의하여 보완되지 않으면 안된다. 지급능력은 소득보다 오히려 지출에 의하여 측정하는 것이 더욱 합리적이라고 생각할 수도 있다. 왜냐하면 개인의 경제적 후생은 구체적으로 소비지출에 의하여 °절되며 축적한 재산은 소비목적에 사용되지 않는 한 그 가치가 나점라 축은 점라고

64) Ibid., p. 1044.
65) 차병권, 전게서, pp. 329-330.
66) 정종섭, 전게서, p. 1044.

생각할 수도 있기 때문이다.[67] 지급능력의 측정기준과 그에 따르라 합리적 조세배분에 관한 문제는 19세기 중엽 이잘 표시이론에 경제후생이론을이 함으로써 내부분적으로 해결되었다. 즉 능력설은 희생을 기초로 하여 과세를 정당화시켰던 것이조세 지급능력을 개인적 희생에 의하여 평가, 비교하고 희생의 형태 및 양상에 관한 고려를 토대로 하여 세율구조를 조한 조세배분에 관한 실천적 과제를 해결하고자 력을던 것이조세 존 스튜어트 밀은 과세의 공괕한 납세자의 균등희생에서 실나타다고 생각력을고, 또 그면은 최소희생이라는 후생적 요구를 충족시킨다고 보았다. 즉 세율을 지급능력의 지표인 개인적 희생도는 롼을 표절하여 적후사람들의 절대적 희생이 균등하여질 때 과세의 공괕한 실나타다고 보았던 것이조세 또 그것은 사회 전체의 최소희생을 의미한다고 생각하였다.[68]

능력원리에 따라 조세부담의 공평을 실현하려면 수평적 공평과 수직적 공평이 이루어져야 한다. 수평적 공평은 동일한 경제적 능력을 가진 사람들은 동일한 액의 조세를 부담하여야 한다는 것이고, 수직적 공평은 상이한 경제적 능력을 가진 사람은 상이한 액의 조세를 부담하여야 한다는 것이다.[69] 동일한 지급능력을 갖는 사람들은 균등한 조세를 부담하게 되고, 지급능력이 다르면 차별적 조세부담이 배분된다. 수평적 공평과 수직적 공평은 모두 동등한 대우를 하여야 한다는 동일한 원칙을 추구하고 있다. 동등한 부담능력을 갖고 있더라도 과세상 차별적으로 다루어져 수평적 공평이 저해되는 경우가 있으므로 응능과세가 수평적 공평이 달성되지 않으면 수직적 공평이 어떻게 고려되든 공평한 부담배분이 될 수 없다고 할 수 있다.[70] 만약에 두 명의 납세자가 모든 관계되는 면에서 동등하지만 한 명의 납세자가 의미있게 더 많은 조세를 납부한다면 그 조세구조는 수평적 형평이 부족한 것이다.[71]

현대 재정의 주류는 능력설에 기초하고 있다. 헌법재판소도 기본적으로 능력설의 입장을 취하고 있다. 그러나 다양한 종류와 형태의 개별조세에서 개별조세의 특성을 무시하고 일률적으로 담세력원리만을 관철하는 것도 문제가 있다. 법적으로는 다양한 조세가 가지는 개개의 성질에 따라 그에 적합한 이익원리 또는 담세력원리를 채택한다.[72]

헌법재판소는

---

67) 차병권, 전게서, pp. 332-333.
68) Ibid., p. 333-334.
69) 정종섭, 전게서, p. 1044.
70) 차병권, 전게서, p. 332.
71) John L. Mikesell, Fiscal Administration, Seventh Edition, Thomson Wadsworth, 2007, p. 302.
72) 정종섭, 전게서, pp. 1044-1045.

[헌법 제11조 제1항에 규정된 평등원칙의 세법영역에서의 구현이라 할 수 있는 조세평등주의는 조세의 부과와 징수를 납세자의 담세능력에 상응하여 공정하고 평등하게 할 것을 요구하며 합리적 이유없이 특정의 납세의무자를 불리하게 차별하거나 우대하는 것을 허용하지 아니한다...어떤 사항을 증여로 의제하여 과세할 것인지는 원칙적으로 입법자의 형성의 자유에 속한다. 그러나 증여세제의 본질에 반하는 자의적 방식으로 또는 특정의 납세의무자들을 합리적 이유없이 차별하거나 우대한다든지 하는 방식으로 증여의제제도를 마련하는 것은 조세법률주의와 조세평등주의라는 헌법적 한계를 벗어나는 것으로서 위헌임을 면할 수 없다...이 사건 법률조항은 증여세의 상속세 보완세적 기능을 관철하는 데에만 집착한 나머지, 배우자상속과 이혼시 재산분할의 재산관계의 이와 같은 본질적이고도 다양한 차이점을 무시하고 이를 동일하게 다루고 있다. 따라서 이 사건 법률조항은 "같은 것을 같게, 다른 것을 다르게"라는 평등의 규준을 어기고, 본질적으로 다른 것을 같게 다룸으로써 자신의 실질적 공유재산을 청산받는 혼인당사자를 합리적 이유없이 불리하게 차별하는 것이므로 조세평등주의에도 위배된다]라고 판시하고 있다.[73]

위 결정은 조세평등주의는 조세의 부과와 징수를 납세자의 담세능력에 상응하여 공정하고 평등하게 할 것을 요구한다고 한다. 위 결정은 조세의 부과와 징수를 공정하고 평등하게 하려면 납세자의 담세능력에 상응하여야 한다고 함으로써 능력설의 입장을 취하고 있다. 위 결정은 어떤 사항을 증여로 의제하여 과세할 것인지는 원칙적으로 입법자의 형성의 자유에 속한다고 하면서도 조세법률주의와 조세평등주의라는 헌법적 한계를 벗어날 수 없다고 한다. 위 결정은 조세평등주의는 합리적 이유없이 특정의 납세의무자를 불리하게 차별하거나 우대하는 것을 허용하지 아니한다고 한다고 함으로써 조세평등주의의 내용으로 차별금지를 제시하고 있다. 위 결정은 평등의 규준은 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하는 것이라고 한다. 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하라는 평등의 규준에 의하면, 본질적으로 다른 것을 같게 다루면 차별이 되고 평등의 규준에 어긋난다. 이러한 논리에 따라 이 사건 법률조항은 증여세의 상속세 보완세적 기능을 관철하는 데에만 집착한 나머지, 배우자상속과 이혼시 재산분할의 재산관계의 본질적이고도 다양한 차이점을 무시하고 이를 동일하게 다루고 있기 때문에 조세평등주의에 위배된다는 것이다. 위 결정은 조세평등주의는 차별금지를 내용으로 하고 있는데, 무엇이 차별에 해당하는지 여부의 판단기준은 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하라는 공식이라고 한다. 위 결정은 조세평등주의에 관하여 수평적 공평과 수직적 공평이라는 용어를 사용하고 있지는 않다. 그 대신 평

73) 헌재 1997.10.30. 96헌바14.

등의 원칙의 일반적인 내용이 되는 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하라는 공식을 활용하고 있다. 그런데 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하라는 공식을 조세에 적용하면 조세의 부과에 있어서 수평적 공평과 수직적 공평을 이루어야 한다는 것이 된다. 같은 것을 같게 취급하라는 것은 수평적 공평을 말하는 것이고, 다른 것을 다르게 취급하라는 것은 수직적 공평을 말하는 것이다. 헌법재판소가 조세의 분야에서 평등의 원칙을 판단할 때에는 수평적 공평과 수직적 공평을 언급하는 것이 바람직하다.

헌법재판소는

[조세평등주의는 정의의 이념에 따라 "평등한 것은 평등하게", 그리고 "불평등한 것은 불평등하게" 취급함으로써 조세법의 입법과정이나 집행과정에서 조세정의를 실현하려는 원칙이라고 할 수 있다]라고 판시하고 있다.[74]

위 결정은 조세평등주의를 정의의 이념과 관련시키고 있다. 위 결정은 정의의 이념은 평등한 것은 평등하게, 그리고 불평등한 것은 불평등하게 취급하라는 것을 그 내용으로 한다고 한다. 위 결정은 평등의 원칙과 정의의 이념을 관련시키고 있다. 위 결정이 들고 있는 정의의 이념의 내용인 평등한 것은 평등하게, 그리고 불평등한 것은 불평등하게 취급하라는 것은 헌재 1997.10.30. 96헌바14의 결정이 말하는 같은 것을 같게, 다른 것을 다르게 취급하라는 것과 동일한 내용이다.

(3) 실질과세의 원칙

실질과세의 원칙은 경제적 실질에 따라 능력에 맞는 공평한 조세부담을 과하려는 과세입법 및 세법적용상의 원칙이다.[75] 실질과세의 원칙은 과세요건사실에 대한 조세법의 적용에 있어서 법률상의 형식과 경제적 실질이 서로 일치하지 않는 경우에 그 경제적 실질에 따라 과세하는 것을 말한다. 실질과세의 원칙은 실질귀속의 원칙과 실질계산의 원칙을 내용으로 한다. 실질귀속의 원칙은 과세물건이 형식상 귀속하는 자와 실질상 귀속하는 자가 다를 경우에는 후자에게 귀속하는 것으로 보고 과세하는 것을 말하고, 실질계산의 원칙은 과세물건을 인식함에 있어서 과세거래의 형식과 실질이 일치하지 않는 경우에는 실질에 따라 과세하는 것을 말한다.[76]

---

74) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.
75) 성낙인, 전게서, p. 950.

헌법재판소는

[실질과세의 원칙은 법률상의 형식과 경제적 실질이 서로 부합하지 않는 경우에 그 경제적 실질을 추구하여 그에 과세함으로써 조세를 공평하게 부과하겠다는 것이나 거기서 말하는 실질의 의미가 반드시 명확한 것도 아닐 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 형식상의 외관이나 명목에 치중하여 과세하는 것이 오히려 공평한 과세를 통한 조세정의의 실현에 부합되는 경우도 있을 수 있다. 그렇기 때문에 국세기본법 제3조 제1항 단서에서는 같은 법 제14조에 규정한 실질과세의 원칙에 대한 예외를 단행세법에서 규정할 수 있도록 길을 터놓고 있는 것이다]라고 판시하고 있다.[77]

위 결정은 실질과세의 원칙은 조세를 공평하게 부과하기 위한 것이라고 한다. 그런데 경우에 따라서는 실질과세의 원칙을 적용하는 것보다 형식상의 외관이나 명목에 치중하여 과세하는 것이 오히려 공평한 과세가 될 수 있다고 한다. 그래서 이 경우에는 실질과세의 원칙에 대한 예외를 인정할 수 있다고 한다. 실질과세의 원칙은 조세평등주의의 파생원칙이다.[78] 헌법재판소는 실질과세의 원칙을 헌법원리로 끌어 올려 조세부담의 공평원리의 한 내용으로 포함시키고 있다.[79]

헌법재판소는

[조세평등주의의 이념을 실현하기 위한 법 제도의 하나가 바로 국세기본법 제14조에 규정한 실질과세의 원칙이라고 할 수 있다...조세평등주의 및 그 파생원칙인 실질과세의 원칙에 비추어 볼 때...헌법이 규정한 평등의 원칙과 차별금지의 원칙의 조세법상 표현이라고 할 수 있는 조세평등주의와 그 실현수단인 실질과세의 원칙에 위반된다고 할 수 있다. 그러나 조세평등주의의 이념을 실현하기 위한 실질과세의 원칙은 조세회피의 방지 또는 조세정의의 실현을 위하여 경우에 따라서는 예외 내지 특례를 인정할 수 있다]라고 판시하고 있다.[80]

위 결정은 실질과세의 원칙은 조세평등주의의 이념을 실현하기 위한 법제도라고 하고 있다. 또한 위 결정은 실질과세의 원칙은 조세평등주의의 파생원칙이라고 하고 있다. 또한 위 결정은 실질과세의 원칙은 조세평등주의의 실현수단이라

76) 정종섭, 전게서, p. 1045.
77) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.
78) 성낙인, 전게서, p. 950.
79) 정종섭, 전게서, p. 1045.
80) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.

고 하고 있다. 위 결정이 사용하고 있는 표현인 조세평등주의의 이념을 실현하기 위한 법제도, 조세평등주의의 파생원칙, 조세평등주의의 실현수단은 엄밀히 따지면 동일한 의미라고 볼 수 없지만 서로 관련된 것들이다. 위 결정에서 확인할 수 있는 것은 실질과세의 원칙은 조세평등주의와 밀접히 관련되어 있다는 점이다.

헌법재판소는

[이 사건 심판의 대상인 위 법률조항은 이미 위에서 지적한 바와 같이 명의신탁제도가 조세회피의 수단으로 악용되는 사례가 허다하기 때문에 이를 효과적으로 방지하기 위하여 조세법상의 대원칙인 실질과세의 원칙을 희생시키면서 명의신탁을 이용한 조세회피 내지 조세포탈을 원천적으로 봉쇄하겠다는 것이 그 입법의도이다...위 법률조항에서는 국세기본법 제3조 제1항 단서의 규정에 따라 실질과세의 원칙에 대한 예외 내지 특례를 둔 것으로 이해된다. 그렇다면 위 법률조항이 실질과세의 원칙에 대한 예외를 설정한 것만으로 위헌이라고 단정하기는 어렵다고 할 것이다. 다만, 증여의 은폐수단이 아닌 진정한 의미의 명의신탁에 대하여도 증여로 의제함으로써 생길 수 있는 위헌의 소지를 제거할 수 있는 대책은 있어야 할 것이다...이 사건 심판의 대상이 된 위 법률조항은 조세법률주의 및 조세평등주의의 이념에 비추어 헌법위반의 소지가 있다. 더구나 실질소유자와 명의자의 불일치라는 결과만을 중시하여 모든 경우를 막론하고 무차별적으로 증여의제하는 것은 재산권보장의 원리와 평등의 원칙에 위배될 소지가 있다. 그러나 명의신탁이 증여의 은폐수단으로 악용되는 조세현실을 방치할 수도 없고 실질과세의 원칙에 대한 예외규정의 설정이 전혀 금지되는 것도 아니다]라고 판시하고 있다.[81]

위 결정은 실질과세의 원칙이 조세평등주의와 밀접히 관련되어 있음을 인정하면서도 실질과세의 원칙에 대한 예외를 설정할 수 있다고 하고 있다. 실질과세의 원칙은 조세평등주의와 밀접히 관련되어 있는바, 실질과세의 원칙에 대한 예외를 인정하게 되면 조세평등주의에 대한 위반의 문제가 생기게 된다. 하지만 위 결정은 실질과세의 원칙에 대한 예외를 설정할 수 있다고 한다.

헌법재판소는

[토초세는 양도소득세와 같은 수득세의 일종으로서 그 과세대상 또한 양도소득세 과세대상의 일부와 완전히 중복되고, 양세의 목적 또한 유사하여 어느 의미에서는 토초세가 양도소득세의 예납적 성격을 가지고 있다고 봄이 상

81) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.

당한데도, 구 토초세법 제26조 제1항과 제4항이 토초세액 전부를 양도소득세에서 공제하도록 규정하지 아니하였으므로, 위 양세의 중복부분은 이중과세에 해당하여 조세법률주의상의 실질과세의 원칙에 반한다]라고 판시하고 있다.[82)]

위 결정은 실질과세의 원칙을 조세법률주의의 내용으로 파악하고 있다. 그리고 위 결정은 이중과세는 실질과세의 원칙에 반하는 것이라고 하고 있다. 실질과세의 원칙을 조세법률주의의 내용으로 파악하는 입장은 실질과세의 원칙을 조세평등주의와 관련시키는 입장[83)]과 대조를 이룬다. 실질과세의 원칙에 관하여 헌법재판소의 입장은 2가지가 병존하고 있다. 실질과세의 원칙을 조세평등주의와 관련시켜서 실질과세의 원칙은 조세평등주의의 이념을 실현하기 위한 법제도, 조세평등주의의 파생원칙, 조세평등주의의 실현수단이라는 입장과 실질과세의 원칙을 조세법률주의의 내용으로 파악하는 입장이 병존하고 있는 것이다. 실질과세의 원칙이 조세법률주의의 내용 내지 파생원칙인지 아니면 조세평등주의의 내용 내지 파생원칙인지 헌법재판소의 입장이 일치되어 있지 않다. 조세법률주의와 조세평등주의의 관계 또한 문제가 된다. 조세법률주의를 법치주의의 조세법상의 표현으로 보고, 조세평등주의를 평등의 원칙의 조세법상의 표현으로 본다면 조세법률주의와 조세평등주의의 관계는 법치주의와 평등의 원칙의 관계와 같을 것이다. 법치주의와 평등의 원칙이 밀접히 관련되어 있지만 양자를 완전히 동일시할 수는 없다. 따라서 실질과세의 원칙을 조세법률주의의 내용 내지 파생원칙으로 이해하는 입장과 실질과세의 원칙을 조세평등주의의 내용 내지 파생원칙으로 이해하는 입장은 차이가 있다. 헌법재판소는 이 문제를 명확히 하여야 할 것이다. 그리고 이중과세는 실질과세의 원칙에 반하는 것이라고 이해하는 입장은 이중과세는 실질적 조세법률주의에 위반되며, 이중과세를 위헌으로 만드는 기본권보장의 헌법이념과 이를 뒷받침하는 헌법상 요구되는 제원칙으로 헌법 제37조 제2항(과잉입법금지원칙)을 들고 있는 입장[84)]과 차이가 있다. 이중과세는 실질과세의 원칙에 반하는 것이라고 이해하는 입장과 이중과세는 헌법 제37조 제2항(과잉입법금지원칙)에 반하는 것이라고 이해하는 입장이 병존하고 있는 것이다. 헌법재판소는 이 문제를 명확히 하여야 할 것이다.

---

82) 헌재 1995.7.27. 93헌바1,3,8,13,15,19,22,37,38,39,52,53(병합), 토지초과이득세법 제8조 등 위헌소원.
83) 헌재 1989.7.21. 89헌마38.
84) 헌재 1997.12.24. 96헌가19.

Ⅵ. 결론

지금까지 본 논문의 분석의 대상이 된 헌법재판에서 문제가 되었던 것들을 중심으로 상속세 및 증여세법에 관한 헌법상의 중요한 문제들을 살펴 보았다. 상속세 및 증여세법에 관한 헌법상의 중요한 문제들 중에는 본 논문이 다루지 않은 것들도 있지만 그러한 것들은 분석의 집중을 위하여 제외하였다. 본 논문이 다룬 상속세 및 증여세법에 관한 헌법상의 중요한 문제들은 조세법률주의, 기본권의 본질적 내용 침해금지, 편의주의, 정의의 원칙, 이중과세, 조세평등주의, 실질과세의 원칙에 관한 것들이다. 이러한 문제들은 앞으로도 계속하여 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판에서 다루어질 것이기 때문에 중요한 것들이다. 이러한 문제들은 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판 뿐만 아니라 상속세 및 증여세법 이외의 조세법에 대한 헌법재판에서도 매우 중요한 문제들이다. 그런데 이미 본 바와 같이 어떠한 문제들에 관하여는 헌법재판소 자체의 입장이 일치되지 못하고 있다. 앞으로 계속적인 연구가 필요한 이유이다. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판 그리고 더 나아가 조세법 전반에 대한 헌법재판에서 문제가 되는 것들은 궁극적으로 헌법의 이론과 헌법의 해석에 의하여 해결되어야 하지만 헌법의 이론과 헌법의 해석 못지 않게 조세법의 이론과 조세법의 해석의 도움이 필요하고 조세학의 이론의 도움이 필요하다. 다시 말하면 조세법에 대한 헌법재판에서 문제가 되는 것들을 해결하기 위하여는 헌법의 이론과 헌법의 해석, 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론의 도움이 필요하다. 예를 들면, 조세부담에 있어서의 수평적 공평과 수직적 공평의 문제, 이중과세의 문제, 실질과세의 원칙의 문제 등은 헌법의 이론과 헌법의 해석 뿐만 아니라 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론의 도움이 필요하다. 상속세 및 증여세법에 대한 헌법재판소의 결정들을 보면 비록 헌법재판소 자체의 입장이 일치되지 못하고 있는 것들도 있지만 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론을 헌법적인 수준으로 끌어 올리기 위하여 많은 노력을 기울이고 있음을 확인할 수 있다.

그런데 이러한 노력이 쉬운 일은 아니다. 조세에 관한 헌법의 규정이 얼마 되지 않고, 조세에 관한 헌법의 규정의 내용이 명확하지 않은 상태에서 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론을 헌법적인 수준으로 끌어 올리는 것은 어려운 작업이다. 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 것들이 모두 헌법의 내용이 되는 것은 아니다. 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 것들 중에서 헌법의 규정과 관련된 것들만이 헌법의 내용으로 된다. 따라서 조세법에 대한 헌법재판에서 제기된 문제들을 해결하기 위하여는 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 것들

을 헌법의 규정과 관련된 것들과 그렇지 않은 것들로 구분하는 작업이 필요하다. 이러한 작업의 결과 어떤 것들은 헌법의 내용으로 되고, 다른 것들은 헌법과는 무관한 것이 된다. 헌법의 내용으로 된 것들은 헌법재판에서 위헌심사의 기준이 되고, 헌법과 무관한 것들은 헌법재판에서 위헌심사의 기준이 되지 못한다. 조세부담에 있어서의 수평적 공평과 수직적 공평의 문제, 이중과세의 문제, 실질과세의 원칙의 문제 등이 헌법의 규정과 관련되어 있는가, 만약 이러한 문제들이 헌법의 규정과 관련되어 있다면 헌법의 어느 규정과 관련되어 있는가 하는 것은 여전히 해결되어야 할 문제이다. 이러한 문제들을 헌법의 규정과 관련시킨다면 우선 조세법률주의, 평등의 원칙, 과잉입법금지의 원칙 등을 생각해 볼 수 있겠는데, 조세부담에 있어서의 수평적 공평과 수직적 공평의 문제, 이중과세의 문제, 실질과세의 원칙의 문제 등이 어떠한 논리로 조세법률주의, 평등의 원칙, 과잉입법금지의 원칙 등과 관련되어 있는지 밝히는 것은 쉬운 일은 아니다. 헌법은 수평적 공평과 수직적 공평, 이중과세, 실질과세의 원칙이라는 용어를 명시적으로 사용하고 있지 않다. 더군다나 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론이 제공해 주는 용어들이 헌법상의 용어들과 정확히 일치하지 않기 때문에 어려움이 가중된다. 조세법의 이론과 조세법의 해석, 조세학의 이론에서는 공평이라는 용어를 사용하고 있는데, 공평이라는 용어와 평등이라는 용어가 완전히 일치하는 용어로 보기는 힘들다. 공평을 평등과 관련시키기 위하여는 공평에 관한 이론과 평등에 관한 이론을 선행적으로 검토하여야 하는데, 이들 이론은 법철학적인 이론과 관련되어 있다. 정의와 평등의 관계도 사정은 동일하다. 정의를 평등과 관련시키기 위하여는 정의에 관한 이론과 평등에 관한 이론을 선행적으로 검토하여야 하는데, 이들 이론도 법철학적인 이론과 관련되어 있다. 이들 이론을 모두 검토하여야 공평, 정의, 평등이 서로 관련되어 있다는 것을 확인할 수 있다. 그때 수평적 공평과 수직적 공평이 조세평등주의의 내용이 됨을 알 수 있게 된다. 이중과세의 문제는 헌법 제37조 제2항의 과잉입법금지의 원칙과 관련된 것인지 아니면 실질과세의 원칙과 관련된 것인지 아니면 양자 모두와 관련된 것인지 헌법재판소도 입장이 일치되지 않고 있다. 실질과세의 원칙도 조세법률주의와 관련된 것인지 아니면 조세평등주의와 관련된 것인지 아니면 양자 모두와 관련된 것인지 헌법재판소도 입장이 일치되지 않고 있다. 위에서 본 것들은 모두 조세법에 관한 헌법재판에서 제기된 문제들을 해결하는데 있어서 직면하는 어려움들이다. 이러한 어려움들을 해결하기 위하여 꾸준한 노력이 필요하다.

참고문헌

권영성, 개정판 헌법학원론, 법문사, 2007.

김 강, 국제적 이중과세의 배제-외국세액 공제제도를 중심으로-, 서울대학교 대학원 법학석사학위논문, 1987.

김대환, 기본권의 본질적 내용 침해금지에 관한 연구, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 1998.

김병화, 위임입법의 통제에 관한 연구, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 1999.

김철수, 제19전정신판 헌법학개론, 박영사, 2007.\

성낙인, 제10판 헌법학, 법문사, 2010.

소순무, "조세법의 헌법적 조명", 헌법문제와 재판(하), 재판자료 제77집, 법원도서관, 1997.

오세혁, 규범충돌 및 그 해소에 관한 연구-규범체계의 통일성과 관련하여-, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2000.

윤진수, "명의신탁에 대한 증여세의 과세와 평등원칙-헌법과 세법 및 사법의 관계", 행솔 이태로 교수 화갑기념논문집 조세법의 논점, 1992.

이상신, 조세법률주의에 관한 연구-위임입법의 한계를 중심으로-, 서울대학교 대학원 법학 석사학위논문, 1994.

정종섭, 제5판 헌법학원론, 박영사, 2010.

정종욱, 실질과세 원칙에 관한 연구, 서울대학교 대학원 법학석사학위논문, 1996.

차병권, 제2전정판 재정학개론, 박영사, 1992.

최대권, "기본권의 제한 및 한계에 관한 연구", 서울대학교 법학, 제22권 3호, 1981.

_____, "입법의 원칙", 서울대학교 법학, 제25권 4호, 1984.

황도수, 헌법재판의 심사기준으로서의 평등, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 1996.

Aristotle, The Nicomachean Ethics, Book Ⅴ, Penguin Books, 2004(위 책은 J. A. K. Thomson에 의하여 1953년에 번역된 것임).

Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, The University of Chicago Press, 1963, 이병훈 역, 법철학, 교육과학사, 1996.

Carl Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen: Interternati-onaler Universitätsverlag, 1950, 34 S. auch in: Verfassungsrechtliche Aufsä-tze aus den Jahren 1924-1954. Materia lien zu einer Verfassungslehre, Berlin: Duncker & Humblot, 1958, 3.Aufl., 1985, S. 386-429, 김효전옮김, 유럽법학의 상태, 교육과학사, 1994.

Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8.Aufl.1973, 최종고 번역, 제3판 법철학, 삼영사, 2007.

John L. Mikesell, Fiscal Administration, Seventh Edition, Thomson Wadsworth, 2007.

Karl Larenz, Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik, München: C. H. Beck, 1979, 양창수 역, 정당한 법의 원리, 박영사, 1986.

Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht des Bundesrepublik Deutschland, C .F. Müller, 20.Aufl.1995, S. 223 ff.와 이 책에 대한 번역서인 계회열 역, 통일 독 일헌법원론, 박영사, 2001.

Konrad Hesse, Bestand und Bedeutung der Grundrechte, 계희열 역, 헌법의 기초이론, 삼영사, 1985.

Konrad Hesse, Gleichheit und Freiheit als Grundprinzipien heutiger staatlicher Ordnung in: Individiuum und Kollektiv, Freiburger Dies Universitatis Bd.9, S. 79 ff., 계희열 역, 헌법의 기초이론, 삼영사, 1985.

Paul R. McDaniel and Hugh J. Ault, Introduction to United States International Taxation, Kluwer Law International, 1998.

ABSTRACT

A Study on the Constitutional Law Issues in Inheritance Tax and Gift Tax Law

Jeong Sang Ik*

This article has studied the constitutional law issues in inheritance tax and gift tax law including the concept and the type of inheritance tax and gift tax. This article has studied the decisions of the Constitutional Law Court about inheritance tax and gift tax law. The Korean Constitutional Law provides that the type of tax and tax rate should be determined by law. The Constitutional Law Court deals with the disputes relrt ng to the iw Copretrt de of articles of the constitutional law about inheritance tax and gift tax. The disputes relrt ng to the iw Copretrt de of articles of the constitutional law about inheritance tax and gift tax are very difficult. As the resultss so many legal problems have come iw the history of the constitutional law litigat de iw Korea. Koreans have iw Coests about these legal problems. Articles of the constitutional law about inheritance tax and gift tax have very important mean ngs for protecting the fundamental rights. This article has tried to analyse many legal problems about inheritance tax and gift tax law. Of many legal problems, the principle that the type of tax and tax rate should be determined by law and the principle of equality are very important. This article has the purpose to give perspectives about the constitutional law issues in inheritance tax and gift tax.

▶ Key words ◀

inheritancetax, gift tax, the rule of law, the fundamental rights, the delegation of legislation, double taxation, the principle of equality.

* Professor at College of Law Hongik University.